第三節 新穎性

准予專利之發明應具備新穎性（novelty）。專利法之新穎性及進步性判斷，係以先前技術（prior art）為比較對象。所謂的先前技術，係指申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術[1]。

值得注意的是，雖然均已「先前技術」為判斷新穎性及進步性之標準，惟二者之範圍未必完全相同（詳如「進步性」之討論）。

第一項 法定新穎性喪失事由

同於其他國家立法例，我國專利法雖要求發明應符合新穎性要件，但未直接定義何謂新穎性，而於第 22 條第 1 項以負面表列方式規定欠缺新穎性之情況，包括：（a）申請前已見於刊物；（b）申請前已公開實施；（c）申請前已為公眾所知悉者。

第一款 新穎性喪失之態樣

一、公開於刊物

專利法之條文雖稱「刊物」，但不限於期刊或書籍，舉凡會議論文、廣告、傳單、型錄均屬之，不問其為印刷、手繪公開的紙本、電子版本、光碟、照片、微影片（microfilm）或其他媒體之儲存形式、學生論文、談話記錄、課程內容、演講文稿；在研討會上的海報揭示發明之技術內容，雖然之後未曾以任何方式再發表該等技術內容，亦屬公開於刊物[2]。

另外，所謂公開於刊物，亦包括專利申請案之公開（第 37 條第 1 項）及公告（第 47 條第 1 項）。先申請案若經撤回，且未早期公開者，仍不生第 23 條本文擬制新穎性喪失效果；反之，先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖示所載明之發明內容經公開或公告，即便其中部分內容經過修正或更正而被刪除，該被刪除部分仍得作為引證文件[3]。

二、公開實施及公知

所謂的公開實施，乃公然實施發明，亦即發明處於可被不特定多數人知悉而實施者，例如：公開銷售或販賣之要約行為；又如，參觀工廠時，物或方法之實施能為公眾得知其結構或步驟者[4]。

---

[1] 專利審查基準（2013 年版），頁 2-3-3。

[2] 專利審查基準（2013 年版），頁 2-3-3。

[3] 專利審查基準（2013 年版），頁 2-3-173。

[4] 專利審查基準（2013 年版），頁 2-3-6。

所謂的公知，係指公開於刊物、公開實施以外之其他技術揭露狀態。知悉者之多寡未必當然決定公開實施或公知與否，使用的狀態雖只有少數人知悉，但在不能期待有保密狀態者，仍屬公開實施或公知[5]。

<<最高行政法院判決，93 年判字第 1701 號，民國 93 年 12 月 30 日>>

上訴人主張，按專利法第 20 條規定「申請前已見於刊物」，是引證資料是否在「系爭案之申請日 87 年 2 月 27 日以前已公開發行」，達於不特定之多數人足以閱讀之狀態，係引證資料具有證據能力之關鍵，然引證資料係錦榮機器廠所印製之產品型錄，而非觀念上之一般公開發行刊物，應歸類於一般之私文書，且僅有一冊，並非某固定期間相繼出版之刊物，故其本身之是否具證據能力尚須配合其他證據才得完整，亦方可得到法定之證據能力....。

（最高行政法院見解）系爭案申請專利範圍為一種「竹製百葉簾葉片之製造方法」，其主要加工程序為：...。查卷附引證資料即錦榮機器廠之「錦榮竹地板／竹壁板整廠機械」型錄，係錦榮機器廠為介紹其產品所印行之產品型錄，除封面及背面外，內頁共 18 頁....第 3、4 頁以圖、文（中英文）載述竹地板、竹壁板生產流程：「原竹（以三年生之竹....為適宜）→原竹定長機（截取所需原竹尺寸）→外竹節修平機（修平外竹節）→原竹鋸片機（經由本機鋸切成竹條）→連環式雙面修平機（經本機雙面修平竹條內竹節及外竹青）→四面修平粗加工機（竹條四面粗加工致大約所需尺寸）→乾燥機（粗加工後之竹條經過防腐防蛀處理送入本機乾燥）→四面修平細加工機（乾燥後之竹條經由本機四面細加工至所需正確尺寸）→鋸機（鋸斷尺寸）→上膠機（竹條上膠）→竹地板油壓式拼板機（油壓拼板成型為竹地板）→雙面修平機（成型後之竹地板雙面給予刨光）→雙邊開槽機（竹地板雙邊開槽，開槽寬度一○ CM 內各尺寸均適宜）→雙頭圓鋸開槽機（竹地板頭尾定尺後再予開槽....）→砂光機（竹地板雙面砂光）→底漆塗裝機（竹地板表面圖上 UV 底漆）→紫外線乾燥機（竹地板塗上 UV 底漆後經過 UV 裝置效果產生光重合反應產生硬化效果）→磨底漆機（竹地板表面磨平底漆）→滾筒式 UV 表面塗裝機（竹地板表面塗上 UV 表面漆）→紫外線乾燥機（竹地板塗上 UV 底漆後經過 UV 裝置效果產生光重合反應產生硬化效果）→成品」。....第十八頁....右下方載明「版權所有・翻印必究 82.1.2000」字樣。....顯見該型錄乃錦榮機器廠於 82 年 1 月間所印製，....為....加強客戶對該產品瞭解與信賴，乃公開該產品整體生產技術流程，印行刊物，以為推廣，自屬一般人可共見共聞之公開宣傳廣告，具有作為異議系爭案之證據資料之證據能力無疑。...

第二款 新穎性喪失與否之判斷標準

具體判斷是否已經達到公開、公用或公知之重點，應包括公眾可近用性（accessible to the public; publicly available）及其內容上是否包含發明技術特徵知

[5] 楊崇森，<<專利法理論與應用>>，2007，修訂二版，頁 92-93。

適當揭露（enabling disclosure）[6]。

易言之，技術資訊若以任何方式呈現而處於公眾可得近用之情況，已構成新穎性喪失事由。因此，所謂的公開、公知或公用，係指於刊物、公開實施或其他任何方式，使技術處於揭露狀態。另外，僅有公開實施行為，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法得知其構造、功能、材料或成分等技術內容者，仍不構成新穎性喪失事由。

<<智慧財產法院行政判決 100 年度行專訴字第 115 號>>[7]

一、事實概要：緣參加人許鴻章前於民國 95 年 2 月 16 日以「減振連接器」向被告申請發明專利，經其編為第 95105195 號審查准予專利後，發給發明第 I293096 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告先於 97 年 11 月 10 日以舉發理由書主張系爭專利違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 22 條第 4 項之規定，復於 98 年 2 月 4 日補充專利舉發理由書，主張系爭專利亦違反專利法第 5 條之規定。案經被告審查，以 100 年 4 月 27 日（100）智專三(三)06020 字第 10020346740 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 100 年 9 月 7 日經訴字第 10006103750 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院並依行政訴訟法第 42 條第 1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

....（參加人/專利權人）主張：...(五)本件台南科學工業園區減振工程細部設計與施工案整體工程期間及系爭專利的減振連接器，就參與的各相關單位及個人均負有保密責任，本件系爭專利的技術特徵為不特定的第三人均無法知悉，並無已公開之情事...

法院判決：...1.按「已見於刊物」與「已公開使用」並不相同，「已見於刊物」乃以公開刊物所載之事項作為判斷之引證，「公開使用」乃公開應用其技術功能之使用行為，而所謂之「公開」係指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態而言。是以建築施工圖之交付固非「公開使用」，但將該施工圖付諸建築施工，由於建築物或廠房施工時，並非處於封閉之狀態，工程師、建築工人、監工、工程包商人員甚或其他工程雜役等不特定人，均有知悉之可能而實際得知其施工技術，而不能期待其保密者，自應認已公開使用（最高行政法院 98 年度判字第 644 號判決要旨參照）。

...依參加人所呈施工現場圍籬照片所示，本件減振工程工地現場（即高鐵橋墩下），係包括由幾乎透空之紅色拉門及可透視的網狀圍籬以界定工地範圍，已足以證明不特定第三人可在減振工程工地現場外圍知悉減振工程工地現場的部分工程，而證人黃啟宗亦證稱：安裝上開減振連器時須使用吊車。如減振連接器吊起來比圍籬高，一般人墊高可以

[6] Janice M. Mueller, An Introduction to Patent Law, 2006, p. 123; Alan L. Durham, Patent Law Essentials, 2004, p. 92, 93, para. 8.9.1.1.

[7] 相近案由事實之判決：最高行政法院 98 年度判字第 644 號判決（關於本判決評釋，參見李素華，新穎性及進步性判斷基礎之先前技術--簡評最高行政法院 98 年度判字第 644 號判決，台灣法學，第 143 期，2010 年 1 月，頁 217-226）。

看到等語（見本院卷(二)第 57、59 頁），而使用吊車安裝時，減振連接器（含基礎板及連接器本體）係由上空吊起依序置入地面下方之壕溝（詳後述），當減振連接器吊起位於地平面之上，不特定第三人均可在減振工程工地現場外圍觀看而得以知悉其內容。又依施工日報表所示，94 年 7 月 30 日及 94 年 12 月 31 日分別安裝減振連接器 8 組及 1264 組（見本院卷(二)第 173、176 頁），同日並有基礎加勁主體（打設鋼板樁、H 型鋼打設等）工程之施作，94 年 7 月 30 日現場工程師包括鴻華公司 9 人、長鴻／清水公司 17 人、世久營造公司 3 人、長鴻營造公司 4 人、信穎營造公司 5 人（見本院卷(二)第 171 頁），94 年 12 月 31 日現場工程師包括鴻華公司 16 人、長鴻/清水公司 12 人、世久營造公司 1 人、長鴻營造公司 3 人、信穎營造公司 5 人、特建營造公司 6 人、中華/新儀 3 人（見本院卷(二)第 174 頁），足見上開減振工程確有眾多協力廠商，且各廠商每日派駐於現場施工人員並非每日相同或固定，而上開協力廠商派駐工地之不特定施工人員均可見聞上開減振連接器之部分構件及安裝過程，不特定第三人更可自工地圍籬外見聞吊車所吊起之減振連接器外觀結構，顯見工地現場縱有人員進出之管制，惟並未採取任何保持施工內容機密性之措施。況證人黃啟宗於本院亦證稱：原告是作監造部分，曾文守是原告所請顧問，與鴻華公司應該不會簽保密契約等語（見本院卷(二)第 56 頁），參加人復未提出任何與其派駐現場施工人員就上開工程施作內容須負保密義務之證明，自難以期待上開現場施工人員負保密之義務，應認原證 18 至 21 所揭示之技術內容「已公開使用」。...

至若公眾近用之技術資訊是否有技術特徵之適當揭露，判斷標準在於，揭露之內容是否已使所屬技術領域具通常知識者不需過度試驗即能製造或使用該發明[8]。若為肯定者，則屬已為公眾所近用之技術特徵，新穎性不備。

<<智慧財產法院民事判決 98 年度民專訴字第 163 號>>

...1.被告所提出之證據 1 乃我國新型專利 M306274 號「溫控風扇式機油冷卻裝置」專利案，其申請日為 95 年 07 月 19 日，公告日為 96 年 2 月 11 日，時間早於系爭專利之申請日（96 年 3 月 13 日），且均為機油冷卻裝置，自得作為適格之比對資料。而就證據 1 第一圖觀察及其專利說明書之記載，證據 1 專利具有一曲軸箱蓋 10，其具有一供曲軸箱傳動軸組設之軸孔（在油表孔 13 下方），該曲軸箱蓋 10 上形成有一導油流道（在 17 入油接頭後方導油管體），該導油流道（在 17 油接頭後方導油管體）具有一外露之入油孔 17 及一連通前述軸孔（在油表孔 13 下方）之出油孔，再者曲軸箱蓋 10 上另形成有一迴油流道（在 18 出油接頭後方導油管體），該迴油流道（在 18 出油接頭後方導油管體）具有一外露之出油孔 18 及一連通前述曲軸箱內部之入油孔 16；一散熱單元 40，其具有一可用於迅速揮發熱源 40，該散熱元件 40 具有連通內部流道之入油孔 411 與出油孔 421，且散熱元件 40 之入油孔 411 可連接曲軸箱蓋 10 之迴油流道（在 18 出油接頭後方導油管體），而散熱元件 40 之出油孔 421 係連接曲軸箱蓋 10 之導油流道（在 17 入油接頭後方導油管體）；

[8] 專利審查基準（2013 年版），頁 2-3-7：審查新穎性時，應以引證文件中所揭露之技術內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時之通常知識，能直接且無歧異得知的內容。

藉此，組構成一可迅速冷卻、且兼具潤滑效果之曲軸箱蓋冷卻裝置者。就上揭證據 1 之溫控風扇式機油冷卻裝置技術特徵與系爭專利相較，顯然證據 1 已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項所有之技術特徵，足認證據 1 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。

2.而證據 2 乃 2006 年 12 月 10 日出版之「摩托車雜誌」第 258 期第 127 頁資料內容，上開雜誌之出版日期早於系爭專利之申請日，自亦得為系爭專利適格之前案比對資料。依上開雜誌所揭露之帕特國際有限公司產品無鰭片積層式機油冷卻器各圖式觀察，該產品結構包括有一曲軸箱蓋，該曲軸箱蓋具有一供曲軸箱傳動軸組設之軸孔，該曲軸箱蓋有一導油流道，且導油流道具有一外露之入油孔及一連通前述軸孔之出油孔，曲軸箱蓋上另有一迴油流道，該迴油流道具有一外露之出油孔及一連通前述曲軸箱內部之入油孔，其中，曲軸箱蓋之導油流道與迴油流道係呈外凸式。另此一產品亦具有一散熱單元，該散熱單元具有一可用於迅速揮發熱源之散熱元件，且該散熱元件具有連通內部流道之入油孔與出油孔，上開入油孔可連接曲軸箱蓋之迴油流道，出油孔則係連接曲軸箱蓋之導油流道。由上述結構可知，證據 2 之無鰭片積層式機油冷卻器顯然已揭露系爭專利申請範圍第 1 項所有之技術特徵，足以證明系爭專利第 1 項請求項不具新穎性。…

(五)依上述證據與原告系爭專利之比對分析，可知原告系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術內容早已經對外公開，原告亦不諱言上開雜誌上所刊登之產品即為其所刊登之本件系爭專利產品，僅主張其在系爭專利申請前對外鋪貨之目的係在測試市場反應云云（參本院卷第 266 頁）。惟原告既不否認上開雜誌中所廣告或介紹之產品即為系爭專利產品，顯然系爭專利之技術內容於申請專利前即已對外公開，此一公開之事實不因原告公開之動機或目的為何有所不同，況本件縱如原告所述係為測試市場反應，顯見其公開之動機乃係基於商業目的，自屬專利法第 94 條第 1 項所規定之不應給予專利消極事由。是本件原告系爭專利既有專利法第 94 條第 1 項規定不應給予專利之無效事由...

第二項 新穎性之審查（部分內容，於進步性一併討論）

同於 EPC 公約第 54 條、德國專利法第 3 條及多數國家，我國對於新穎性認定係採國際新穎性及絕對新穎性（absolute novelty），不採國內新穎性及相對新穎性（qualified novelty）。亦即，發明必須在國內屬於「新的」發明，除此之外，放諸全世界，該發明亦應未曾被發明人本身或第三人所公開、公用及公知，未曾在世界上任何地方及以任何語言或任何形式，諸如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用[9]。

新穎性之判斷基準日乃申請日以前，不包括申請當日及其後之公開情形。若申請人有主張優先權者，新穎性之判斷基準則指優先權日（第 28 條第 4 項）。

[9] 專利審查基準（2013 年版），頁 2-3-3。

第三項 欠缺新穎性之法律效果

發明欠缺新穎性者，應由專利專責機關作成不予專利之處分或由第三人依舉發程序撤銷專利權（第 46 條及第 71 條第 1 項第 1 款）。

第四節 進步性

依循專利制度之目的，欲准予專利之發明應對於所屬技術領域中具通常知識者而言，有其特殊之處。因此，專利保護之發明應具備進步性（inventive step; non-obviousness）。

第一項 進步性之判斷標準

何謂進步性，同於新穎性之立法模式，多數國家專利法未予定義，而是以反面解釋方式處理。亦即，發明之整體（as a whole）與先前技術（prior art）雖有差異，但該發明所屬技術領域之通常知識者（a person skilled in the art; a person having ordinary skill in the art, PHOSITA）依先前技術所能輕易完成者[10]，則不符合進步性要件，前揭內容亦為我國專利法第 22 條第 2 項所明定。

2017 年 7 月我國專利審查基準修正進步性之判斷標準，明文規定進步性判斷步驟如下[11]：

（i）確定申請專利之發明範圍；

（ii）確定相關先前技術所揭露之內容；

（iii）確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；

（iv）確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異；

（v）該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。

美國專利審查及司法實務目前就進步性所採行之一般性準則，係依循 1966 年 *Graham* 案[12]最高法院所建立的法學方法，2007 年 *KSR* 案[13]雖略微修正該法中部分要件之具體適用與判斷標準，惟其並未推翻 *Graham* 案之一般性準則。最高法院於 *Graham* 案中清楚揭示，發明是否具備進步性為法律問題（a question of law），答案之獲悉需仰賴數個基本事實資料（depend on several underlying factual inquiries）。因此，不論是專利專責機關或法院在決定發明之進步性時，應依循如下攸關進步性判斷的四個因素分析之：

---

[10] 專利審查基準（2013 年），頁 2-3-14。

[11] 專利審查基準（2017 年 7 月），頁 2-3-16 以下。

[12] Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).

[13] KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007).

（i）通常知識者之技術水準（level of ordinary skill in the art）；

（ii）先前技術之範圍與內容（scope and content of the prior art）；

（iii）發明與先前技術之差距（differences between the claimed invention and the prior art）；

（iv）進步性判斷之其他客觀因素（secondary considerations）。

德國實務對於進步性之審查，亦是針對前揭因素依序及逐一分析之，其判斷方法步驟相近於美國實務[14]。

第一款 所屬技術領域具通常知識者[15]

發明是否具備進步性，乃以「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」（a person skilled in the art; a person having ordinary skill in the art, PHOSITA）為標準。

2017 年 7 月我國專利審查基準規定，審查進步性時，應客觀的認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，於確定技術水準時，可考量下列因素[16]：

（i）該技術（art）所面臨問題之類型；

（ii）先前技術解決該等問題之技術手段；

（iii）發明所屬技術領域之創新速度；

（iv）該科技（technology）之複雜程度；

（v）該領域（field）實務從事者之教育水準。

---

[14] 關於進步性判斷之法學方法，詳見李素華（2023 年 3 月），從最高行政法院及最高法院之新進判決再論專利權之進步性判斷，台灣法律人，21 期，頁 65-87；李素華、張哲倫（2015），專利進步性判斷之法學方法論-美、德之借鏡及臺灣實務之檢討，月旦法學，242 期，頁 227-259；張哲倫（2018），判斷進步性應界定通常知識者之學理基礎－評最高行政法院 105 年度判字第 503 號判決之啟發暨智慧財產法院之回應，月旦法學，282 期，頁 149-170；呂紹凡（2014），判斷專利進步性要件之再檢討，萬國法律，193 期，頁 41-50；沈宗倫（2013），由專利法教示因果關係論專利進步性：以組合專利與類似組合專利為中心，臺大法學論叢，42 卷 2 期，頁 317-379；陳志遠（2019），論進步性之肯定因素－「反向教示」：以台灣智財法院相關判決為核心，專利師季刊，39 期，頁 147-167。

[15] 熊誦梅，眾裡尋他千百度：談所屬技術領域中之通常知識者--從最高行政法院 98 年度判字第 1277 號判決談起，月旦法學，第 191 期，2011 年 4 月，頁 129-144；宋皇志，論進步性審理之進步空間--智慧財產法院 97 年度行專訴字第 19 號行政判決評析，月旦法學，第 191 期，2011 年 4 月，頁 145-159。關於德國立法例之介紹，參見李素華，進步性判斷之「所屬技術領域中具有通常知識者」-德國立法例之觀點，專利師季刊，第 5 期，2011 年 4 月，頁 38-51。關於進步性判斷之 PHOSITA 認定標準，亦參見 TIPA「智慧財產實務案例評析座談會-專利法上進步性之判斷」，2014 年 11 月 26 日；謝銘洋、李素華（2013），專利侵權訴訟中之進步性與均等論-德國觀點，收錄於智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 2 輯，司法院行政訴訟及懲戒廳，頁 1-49。

[16] 專利審查基準（2017 年 7 月），頁 2-3-17。

個案中，前揭每一因素未必皆存在，可能一或多個因素即具有決定性。若由相關先前技術之內容即足以反映或認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，則可逕行確定該技術水準，無需另外考量上素因素。

所屬技術領域具通常知識之「人」，其為虛擬之人（hypothetical person）[17]，由其眼光與技術標準來比較發明與先前技術間之差距及創新程度。通常知識者非指發明人或創新之人（innovator），而是該技術領域中之通常從業人員[18]，其為該發明所屬技術領域中，具有一般知識及普通技能及執行例行工作、實驗等普通能力之人，能理解、利用申請日或優先權日之前的先前技術[19]。美國法認為，通常知識者之內涵不容忽略「工匠」（mechanic）概念，德國法亦認為，判斷上應包括「專業能力」與「實務經驗」兩部分，前者係由教育或實務工作中所獲得，後者則是藉由實務工作過程所累積，二者在概念上略有不同[20]。

至若通常知識（general knowledge），係指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。

<<智慧財產法院民事判決 99 年度民專上字第 55 號>>

…系爭專利依其說明書之記載係屬拖把用脫水桶結構之創作，其技術領域係生活用品之機械領域，次依引證 1 說明書之記載，引證 1 之創作係一種含水物之脫水裝置，另參酌該創作所欲改良之先前技術，該含水物係包括拖把在內，而依引證 2 說明書之記載，引證 2 之創作係一種拖把絞乾機之新型構造，再依引證 3 說明書之記載，引證 3 之創作係一種濕拖把擠壓裝置，是引證 1、2、3 之技術領域與系爭專利均相同，且系爭專利僅係日用品之簡易結構改良，是系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者係具備機械相關科系之職業技術教育背景或係受有機械訓練之實務工作者。…

<<最高行政法院判決 103 年度判字第 406 號>>

…經濟部智慧財產局所發佈之專利審查基準所載為：『該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術。』此一虛擬之人之建立，對客觀判斷進步性與否至關重要，依上說明，本件既屬製造多結

[17] Claus Dietrich Asendorf, Zu den Aufgaben des gerichtlichen Sachverständigen in Patentnichtigkeitsverfahren, GRUR 2009, 209, 210 (2009)。通常知識者往往非單一技術領域之一人，同於產業實務之研發團隊，因發明涉及之技術內容及其複雜程度，甚而應以不同技術領域之一組人或一個團隊角度來判斷發明之進步性。Claus Dietrich Asendorf, Zu den Aufgaben des gerichtlichen Sachverständigen in Patentnichtigkeitsverfahren, GRUR 2009, 209, 210 f.; Benkard/Asendorf/Schmidt, PatG, 10. Aufl., 2006, § 4 Rdnr. 36.

[18] Life Technologies, Inc. v. Clontech Labs., Inc., 224 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2000).

[19] 專利審查基準（2013 年），頁 2-3-15。

[20] Benkard/Asendorf/Schmidt, a.a.O. (FN **Error! Bookmark not defined.**), § 4 Rdnr. 35, 37.

紗之機械之技術領域，則其所屬技術領域中具有通常知識者，自不限於該專利產品之使用者，尚應包括同一技術領域之競爭者、生產者及公司內從事研發工作者，事屬當然。…

<<智慧財產法院民事判決 104 年度民專上字第 25 號>>

（法院判決）…

(六)至上訴人雖又主張，有關進步性之判斷，應先確立「所屬技術領域中熟習該項技術者之知識水準」，並聲請傳喚證人林暄智，以證明所屬技術領域之人於系爭 I 專利申請時之知識水準云云。然查，發明或新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，即不具進步性而不得取得該發明或新型專利（93 年專利法第 22 條第 4 項、第 94 條第 4 項），所謂「申請前所屬技術領域中具有通常知識者」，係一虛擬之人，指具有申請時該發明（新型）所屬技術領域之一般知識及普通技能之人，且能理解理解、利用申請日之前的先前知識（見經濟部智慧財產局專利審查基準第二篇第三章 3.2.1 ）。換言之，判斷系爭專利是否具進步性，須將時空背景模擬回溯至系爭專利申請時，且須將角色模擬為該領域中之通常知識者，**是此「申請前所屬技術領域中具有通常知識者」僅為一虛擬之人，實無從以傳喚特定之人來建立，是上訴人聲請傳喚林暄智以證明系爭 I 專利申請時之通常知識者之水準，並無調查之必要**。…實則，**因專利審查、舉發階段係由審查人員就專利是否具進步性進行審查，專利訴訟階段係由法官就專利是否具進步性為認定，因此，應由審查人員及法官模擬申請前通常知識者之知識水準，以判斷系爭專利是否具進步性，本院認系爭二專利為申請前所屬技術領域中具有通常知識者所得輕易完成而不具進步性之理由，已詳述如前所載，是上訴人上開主張並無理由，系爭二專利不具進步性應堪認定**。

過往智慧財產法院於訴訟過程（不論是民事或行政訴訟），未界定 PHOSITA 標準或僅以一句「為該發明所屬技術領域中具通常知識者所能輕易完成」即否定專利有效性，嗣後受到最高法院（例如：最高法院民事判決 100 年度台上字第 1804 號）、104 年度台上字第 948 號民事判決）及最高行政法院非難，至最高行政法院 105 年度判字第 503 號判決明確指謫此等疏誤。

<<最高行政法院 105 年度判字第 503 號判決>>

…七、本院按：…

(三)再按判斷申請專利是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，應以申請專利之整體，亦即以每一請求項中專利的整體為對象，而非以請求項各元件之技術特徵為個別比對，但因專利係由各別構件組合而成，各部分構件亦有其技術內容，所以在判斷專利是否具進步性時，不得不依下列步驟判斷之：1、確定被比對專利之專利範圍；2、確定相關先前技術所揭露的內容；3、確定被比對專利所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；4、確認被比對專利與相關先前技術之間的差異；5、該被比對專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及

申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成被比對專利的整體。既言係專利整體為判斷進步性對象，自應注意各該經比對出來的差異技術是否在待解決之客觀問題上，而非與被比對專利無關之技術，按此步驟所為之專利進步性判斷，自合於專利進步性整體判斷之基準。反之，若跳過上開確認被比對專利與相關先前技術之間的差異，逕就被比對專利與相關先前技術直接挑選擇其相異之構件作進步性判斷，反而違反以專利整體為對象判斷之基準。當然，判斷進步性之重點在於「所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成」，自不能過度機械性僅比對差異，或僅僵化強調相關先前技術所揭露之內容有無教示、建議、動機等（即所謂 TSM 法則）而忽略所「能輕易完成」此一要件，自不待言。…

(一)按上開進步性判斷構成要件中「所屬技術領域中具有通常知識者」，為進步性客觀判斷的重要步驟之一。蓋行政法之法規構成要件中，本即存有許多未明確表示且具有流動性質之法律概念，稱為不確定法律概念。對此不確定法律概念，因具有一般性、普遍性、抽象性或多義性而不夠明確，各該構成要件於套用具體事實時，須先將不確定法律概念經過解釋，並予以具體化以便適用。而對於此不確定法律概念，於專利法制上，對許多傳統之技術領域，或是結果較可預期之技術領域而言，多半經由先前技術之提出，即可得知此「所屬技術領域中具有通常知識者」之標準，但對於先進技術、待開發之技術、技術交錯、結果較難預期之技術領域等，特別是當事人有爭執時，行政機關宜先就該不確定法律概念加以解釋後，再予以具體化適用，人民提起行政爭訟，行政法院亦應審查該行政處分之合法性，若特定案件可經由論證而涵攝於不確定法律概念者，行政法院自得對行政機關所為之處分之合法性，為全面之審查。…

(三)所謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據一般性定義係指一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗之普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前之先前技術者而言；至所謂通常知識（generalknowledge），則指該發明所屬技術領域中已知之普通知識，包括習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解之事項（參照經濟部頒專利審查基準）。該具通常知識之人既係一虛擬之人，其並非專利審查官，亦非專利有效性訴訟之法官，更非技術審查官。法條規定此一虛擬之人，其目的在於排除進步性審查之後見之明。依據上開定義「具有通常知識者」可分為知識要件與致能要件，知識要件指：「已知之普通知識，包括習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊」，應非以學歷區分係高中、大學或碩博士，若以學歷定義，則為一定範圍不特定之人，並非虛擬之人。另上開定義「執行例行工作、實驗之普通能力」，亦即具有通常知識者之致能要件，但在訴訟中有何機制或審判輔助機關可以界定申請時之具有通常知識者的致能要件？再者，具有通常知識者此一構成要件在界定上，究係法規範之解釋？或係事實而應予調查、並為舉證之事項？若係舉證事項，則與引證案先前技術之所謂證據如何區別？大略思考即有上述問題存在，所以要確定所屬技術領域中具有通常知識者在實際訴訟操作上，確有一定難度。所以以往審定書或判決書對所屬技術領域中具有通常知識者之論述，通常於確認被比對專利與相關先前技術之間的差異後；在判斷是否能輕易完成被比

對專利的整體步驟間，論述該被比對專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，而未特別就具有通常知識者為何作定義或解釋，**本院亦加以容認。但此一虛擬之人之建立，對客觀判斷進步性與否至關重要，將來智慧財產法院就進步性為判斷時，亦宜先依系爭專利所著重之技術領域、先前技術面臨之問題，解決問題之方法、技術之複雜度及其實務從事者通常水準，確立「具有通常知識者」之知識水準**。則本件證據 1 是否可以證明系爭專利請求項 3 不具進步性，其「具有通常知識者」此一構成要件，並未經令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，經兩造充分攻防行言詞辯論，即有可議。…

針對最高行政法院 105 年度判字第 503 號判決之意旨，2017 年 7 月間智慧財產法院於 105 年度行專更(一)字第 4 號案件審理之際，針對進步性判斷及如何界定 PHOSITA 問題，徵求法庭之友（amicus curiae）意見[21]。

<<智慧財產法院 104 年度行專訴字第 34 號行政判決>>

…按所謂「所屬技術領域中之通常知識者」，其實與民刑事責任應以「一般合理人」為判斷標準，以及較為特別之責任類型，應以「善良管理人」為判斷標準之立法意旨相同，即法院審理案件並非以法官個人之主觀標準為依據，而係以「所屬技術領域中之通常知識者」為判斷標準。就專利事件而言，特別是在進步性之判斷上，所著重者應為技術水平，亦即在專利申請前，以所屬技術領域中具通常知識者之技術水平觀之，倘該專利係運用先前技術顯能輕易完成，即不具進步性。但對許多技術發展已相當成熟，或組合結果較可預期之技術領域而言，除非當事人有所爭執，則由先前技術之提出，即應可判斷所屬技術領域中通常知識者之技術水平為何，正如一般民刑事案件，亦毋須一一敘明何謂「一般合理人」或「善良管理人」之理由相同。此外，專利乃實用技術之發展，並非科學極致之追求，因此實作能力更甚於學歷之累積，故亦非每一件所屬技術領域中之通常知識者均應以學歷及經歷之結合方式加以描述。經查依系爭專利之說明書所載其所欲解決之問題主要在於改良習知具辨識功能之起子頭使用過程易色料脫落、束套膠環易硬化、刮傷缺點；而系爭專利解決問題之技術特點在於透過鋁合金之成型與陽極處理等加工方式，來解決習知具辨識功能之起子頭所存在之問題。由系爭專利說明書所載之先前技術已指出起子頭無論是公、英制或尺寸不同的因素均有取用時易產生混淆而辨識不易之困擾，且起子頭的頸身部位透過塗佈色料或束套膠環等手段形成具有顏色的環面部位均為結構設計之習知技術，即系爭專利雖屬具辨識功能之起子頭，但其創作之重點在於以起子頭辨識環以鋁合金材質經機械加工成型之結構及陽極處理等加工技術，故系爭專利為機械切削及金屬表面處理加工之領域，屬技術發展成熟之領域。因此，被告雖未於審定書中敘明本件所屬技術領域中之通常知識者之標準，但依參加人所提之先前技術，咸信被告係依所屬技術領域中通常知識者之技術水平作為本件進步性之判斷標準。

[21] 網站已經移除（http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1350&catid=161&Itemid=100110）。

惟原告既於本件訴訟中對此有所爭執，本院綜核系爭專利說明書之先前技術記載創作人即原告已有多年從事相關產品製造開發及設計經驗，以及原證 2 之創作人亦為原告，且參加人即舉發人亦有多年開發及設計起子頭之經歷，認系爭專利申請前所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準客觀上應以具有機械成型及材料表面處理之加工知識，並具有多年實務工作經驗之人為標準。至本件進步性之判斷，自亦係以此標準為基礎，併此敘明。…

<<智慧財產法院行政判決 104 年度行專更(一)字第 2 號>>

貳、實體方面：

一、事實概要：

原告於民國 91 年 6 月 14 日以「自動切換器」向被告申請新型專利，經被告編為第 91208868 號審查，於 93 年 3 月 15 日審定准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 227224 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核准時即 90 年 10 月 24 日修正公布、91 年 1 月 1 日施行之專利法第 97 條、第 98 條第 2 項、第 105 條準用第 22 條第 4 項及第 5 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。原告嗣於 100 年 6 月 27 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經被告審查，應准予更正，本件舉發案依該更正本審查，並認系爭新型專利有違同法第 98 條第 2 項規定，乃於 101 年 8 月 27 日以（101）智專三（二）04059 字第 1012088404 0 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（即本件原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部 102 年 1 月 22 日經訴字第 10206092110 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，並以 102 年度行專訴字第 37 號行政判決駁回後，提起上訴。嗣經最高行政法院 104 年度判字第 214 號判決將原判決廢棄，發回本院更為審理。…

（法院判決）六、得心證之理由：

（一）關於本件系爭專利之所屬技術領域中具有通常知識者之界定，應是大學畢業後，從事電腦操作台、訊號切換器與電腦周邊設備製造業 1 至 2 年之工程師，為兩造及參加人所不爭執（參本院更（一）卷 2 第 95 頁言詞辯論筆錄、以及本院更（一）卷 2 第 20 頁反面原告與參加人之本院 104 年度民專上更（一）字第 2 號侵害專利權有關財產權爭議等民事事件準備程序筆錄）。…

觀諸美國或德國訴訟實務，當事人若就進步性有所爭執，不論是質疑專利有效性一方抑或專利權人，通常會提出證據，以建立其認為妥適之通常知識者技術水準。專家證人蒞庭陳述證詞乃慣行作法（often in the form of expert witness testimony）[22]。於此情況，法院應決定專利申請日或優先權日之通常知識者技術水準為何[23]。

[22] MUELLER, *supra* note **Error! Bookmark not defined.**, at 279-280.
[23] DURHAM, *supra* note **Error! Bookmark not defined.**, at 145.

2022 年 8 月最高法院廢棄智商法院判決，認為當事人對於「通常知識」之概念有爭執，法院應使當事人言詞辯論或適當開示心證；最高法院亦指出證據調查的重要性及必要性。

<<最高法院 111 年度台上字第 15 號民事判決>>

四、惟按智慧財產權事件涉及跨領域之科技專業知識，智慧財產及商業法院（下稱智財法院）依智慧財產法院組織法（現名稱為智慧財產及商業法院組織法）第 16 條第 4 項及智慧財產案件審理法第 4 條之規定，配置有技術審查官，使其受法官之指揮監督，依法協助法官從事案件之技術判斷、蒐集、分析及提供意見，且依智慧財產事件審理細則第 16 條規定，審判長或受命法官得命技術審查官製作報告書，該報告書不予公開。且為免智財法院審理是類訟爭事件，就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，與專責機關之判斷歧異，而對當事人造成突襲，並平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益，智慧財產案件審理法第 8 條第 1、2 項規定，法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎；審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。查原審認定乙證 2 之專利案，在步驟 6 時由方式 d 改為方式 a ，係所屬技術領域中具有通常知識者就同一引證文件中能輕易執行者；及乙證 10 之技術中，①將產生條碼之電腦由 POS 終端之電腦變更為支付機構伺服器；②在支付機構伺服器檢查支付清單是否相同步驟之「同時」或「之後」接收行動裝置傳送之支付請求的接收時間點之選擇，均係所屬技術領域中具有通常知識者，依申請時之通常知識能簡單變更者，係屬該領域具有通常知識者均能輕易執行或簡單變更者，惟原審就上開專業知識，未依上揭規定意旨適當揭露及令當事人為辯論，遽為不利上訴人之論斷，其所踐行之訴訟程序，已難謂合。次按當事人聲明之證據，除就其聲明之證據中認為不必要者外，法院應為調查，民事訴訟法第 286 條定有明文。該條但書所謂不必要之證據，係指當事人聲明之證據，與應證事實無關，或不影響裁判基礎，或毫無證據價值，或因有窒礙不能預定調查證據之期間或訟爭事實已臻明瞭且法院已得強固之心證而言。查上訴人主張：系爭產品 A 之華銀 Q 收銀台確有傳送支付清單至付機構伺服器，且支付機構伺服器須核對商店提供之支付資料及付款客戶提供之支付資料相同等語（見原審卷 • 第 18、333、360 頁），並聲請調查華銀 Q 收銀台之系統規格及原始程式碼，以查明其產生支付清單之事實等語（見原審卷 • 第 335 頁），其並於原審 109 年 11 月 9 日準備程序期日聲請命被上訴人提出 SOURCE CODE ，以確認侵權行為事實、系爭產品 A 與系爭產品 C 間之互動等語（見原審卷 • 第 13、15 頁）。似見上訴人是項證據調查之聲請，與系爭產品是否落入系爭專利請求項 1、4、6 範圍內，所關頗切。原審就此未予調查審認，亦未敘明不調查之理由，遽以上訴人未舉證系爭產品未落入系爭專利請求項 1、4、6 範圍內，不構成文義及均等侵權，而為於其不利之判斷，自有可議。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。

<<最高行政法院 111 年度上字第 236 號判決>>

（七）末按，所謂「所屬技術領域具有通常知識者」（person who has the ordinary skill in the art, PHOSITA）乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創作能力如何，必須藉由外部證據資料將其能力具體化，在專利訴訟實務中，爭議之專利其所歸類之技術分類，以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料，當此一虛擬角色之技術能力經由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現時，有關爭議專利之創作是否與已經存在之技術間有顯著之不同、相較於既有或已知之技術而言是否產生顯著之功效，即應透過論理法則與經驗法則，在不違自然法則之前提下加以客觀檢視，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右。法院就專利之進步性論證過程，某種程度上即係將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體化，倘其論證內容不違經驗法則、論理法則或自然法則，即尚難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者之知識水平加以說明。查原審於訴訟程序中，已透過上訴人華懋公司所提證據 2 至 5 所揭露之技術內容，藉以形成「所屬技術領域中具有通常知識者」之技術水準，進而據以認定系爭專利請求項 1、3 具進步性，且其認定無違經驗法則及論理法則，已如前述，尚難認有理由不備之違法。上訴意旨主張：訴願決定與上訴人就發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準已為說明，除內垂吊體部分與先前技術有所差異外，其餘技術特徵全為習知之先前技術，並據以為主張系爭專利不具進步性之基礎，原判決為相反之認定，有違論理法則、證據法則及判決不備理由之違法云云，均無可採。

<<最高法院 111 年度台上字第 186 號民事判決>>

・・・判斷進步性之重點，在於「熟習技術者，運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成」，當不能機械性比對差異，或僅強調相關先前技術所揭露之內容有無教示、建議、動機等（即所謂 TSM 法則），而忽略「能輕易完成」之要件。

(三)發明專利與舉發證據間所存在之差異，為該專利之重要技術特徵，於審查時，應就該特徵是否為舉發證據所揭露，或為所屬技術領域之熟習技術者，以轉用、置換、改變或組合舉發證據等方式，所能輕易完成各情，詳加審酌。蓋進步性審查，不得以發明說明循序漸進、由淺入深之內容，所產生之「後見之明」，即作成能輕易完成之判斷，逕予認定發明不具進步性；而應將發明專利之整體，與舉發證據進行比對，以該發明所屬技術領域之熟習技術者，參酌申請時之通常知識觀點為客觀判斷。所謂熟習技術者，係指一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識，及執行例行工作、實驗之普通能力，而能理解、利用申請日之前之先前技術者而言。熟習技術者之建立，目的在於排除進步性審查之後見之明，對客觀判斷進步性與否，至關重要。

(四)系爭專利申請日為 84 年 10 月 17 日，被證 1、被證 2、被證 3 之公告或公開日，均早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術等情，既為原審所認定，可見關於系爭專利之進步性判斷，應以該專利所屬技術領域之熟習技術者，參酌 84 年 10 月 17 日時之通常知識觀點為客觀判斷，而不得以其後之通常知識觀點為判斷。上訴人就此主張：系爭專利之名詞解讀，應以該專利發明時，相關同業一般技術人員的意見為準；本件有必要引入 20 多年前所屬技術領域中，具有通常知識者，作為專家證人，以澄清各項技術

等語，並聲請訊問盧維藩，以證明系爭專利申請時，通常知識者之技術水平，及引證案能否證明系爭專利不具進步性（分見一審卷(三)163 頁；原審卷(二)385、387、421 至 427 頁、卷(五)267 至 268 頁），依上開規定及說明意旨，自攸關系爭專利之進步性判斷，應予調查審認。惟原判決並未說明其不可採及無調查必要之理由，且乏熟習技術者之認定，即缺少「系爭專利所屬技術領域中，熟習技術者之技術水準」之判斷步驟，逕以上開理由認定系爭請求項不具進步性，除有不適用法規及適用不當外，並屬不備理由。

第二款 先前技術之範圍與內容

專利法未定義進步性判斷之先前技術，用於判斷新穎性之先前技術，原則上應可用來決定發明是否滿足進步性要件[24]，惟應注意，二者仍有不同。

首先，擬制新穎性喪失之事由，不能用於進步性判斷。易言之，申請日及申請後始公開或公告之技術，包含申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利之先申請案，雖能構成新穎性喪失之前案，不能用於進步性判斷[25]。

其次，發明是否滿足新穎性要件時，基本上是以申請日以前所公開、公知或公用之先前技術為比較基礎；相較於此，進步性判斷僅能將「相類領域技術」（analogous art）之先前技術納入考量，其範圍較窄。值得檢討者為，我國專利審查基準似認為二者相同[26]，惟二者實應有別。

易言之，進步性判斷是想像虛擬的通常知識者所處工作環境及其被相類領域之專利權、公開文獻與其他引證文件環繞的客觀環境[27]，自然不能期待通常知識者會近用所有已公開、公知或公用之技術資訊；與進步性判斷有關之先前技術，應僅限於通常知識者欲解決發明之技術問題時，客觀上所能知悉或掌握之技術資訊，此即先前技術中之相類領域技術。

至若相類領域技術之界定，美國法院認為應還原通常知識者從事研發的過程（by seeking to recreate to innovation process of a PHOSITA），以區別哪些先前技術是屬於相類領域技術。依此標準，能符合如下任一情形之先前技術，始為相類領域技術[28]：

（i）該先前技術與發明屬於相近的技術領域（the same field of endeavor as the invention）[29]；

---

[24] MUELLER, *supra* note **Error! Bookmark not defined.**, at 285.

[25] 經濟部智慧財局（2017），專利審查基準，3.2.2.

[26] 經濟部智慧財局（2017），專利審查基準，3.2.2.

[27] DURHAM, *supra* note **Error! Bookmark not defined.**, at 146.

[28] MUELLER, *supra* note **Error! Bookmark not defined.**, at 293-294.

[29] 至若相類領域技術之判斷，同樣為不確定法律概念，美國實務亦不乏個案討論與爭議。例如：申請專利保護之發明為符合人體工學設計的梳子，相類領域技術是否涵蓋牙刷（與梳子同樣有握把），CAFC 多數決

（ii）該先前技術與發明雖屬不同技術領域，但其與發明欲解決之技術問題實質上相當（reasonably pertinent to the same problem as that addressed by the invention）[30]。

進步性判斷時，若未採「相類領域技術」蓋年而將申請日以前之所有先前技術納入，不免有導致「後見之明」的風險；此外，此等進步性審查亦將流於機械性比對發明與先前技術之技術特徵，忽略通常知識者從事研發時客觀上所身處的技術環境。

第三款 發明與先前技術之差距

請求專利保護之發明與先前技術間，在技術上應有「質的差距」，此等差距對通常知識者而言非屬顯而易見，抑或其乃通常知識者無法輕易完成者，始能滿足進步性要求。進步性判斷程序中，「請求保護的發明與先前技術之差距」為核心，因此，不論是專利專責機關或法院，於否定發明之進步性時，均應清楚指出發明整體與先前技術之差異為何[31]。

一、技術差異之認定標準

關於請求保護的發明與先前技術之差距是否為通常知識者所能輕易完成，乃進步性判斷之核心。

詳言之，用來否定新穎性之先前技術，單一引證文件必須揭露發明之所有技術特徵；新穎性之審查，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，亦即一發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對[32]。

反之，進步性判斷則可結合先前技術中之不同引證文件。

蓋進步性判斷時，係以所屬技術領域具通常知識之人為基準，若其依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成申請專利之發明者，該發明之整體即屬顯而易知，應認定為能輕易完成之發明，不符合進步性之要件。

肯定之，持不同意見之 Newman 法官則駁斥多數見解悖離常識，蓋牙刷與梳子根本不同。詳見 *In re Bigio*, 381 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2004).

[30] 與發明不同技術領域之先前技術能被認定為相類領域技術之前提，乃發明人在思索如何解決技術問題時，可合理及符合邏輯的期待，該引證文件會引起發明人之注意。*In re Klein*, 647 F.3d 1343, 1348 (Fed. Cir. 2011).

[31] MUELLER, *supra* note **Error! Bookmark not defined.**, at 297.

[32] 專利審查基準（2013 年版），頁 2-3-7。

因此，相異於新穎性[33]之判斷，進步性之判斷係以發明之整體（as a whole）為基準，亦即審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，判斷申請專利之發明是否能輕易完成[34]。

進步性判斷雖得組合多份文件，但 2017 年 7 月我國專利審查基準修正中明文規定，確認該發明與相關先前技術所揭露內容間的差異時，應選定一個引證（主要引證）與申請專利之發明的技術內容進行差異比對，且不得將二個以上引證予以組合後作為「主要引證」[35]。

通常知識者有無動機在先前技術之基礎完成發明，美國實務從 1851 年的 Hotchkiss 案[36]、1966 年的 Graham 案[37]到 2007 年重要的 KSR 案[38]，就非顯而易見性之判斷建立重要的 TSM 測試標準（teaching, suggestion or motivation）。

2007 年 *KSR* 案以前，實務上一直是依循較為僵化的判斷法則。欲組合不同的相類領域技術來否定發明之進步性，應指出通常知識者會因一定情事而使其有意願（in some fashion, would have been led）結合不同相類領域技術以解決發明之技術問題[39]。因此，認定發明為顯而易見，必須有所謂的 TSM（teaching, suggestion or motivation）作為支持。

2007 年美國最高法院透過 *KSR* 案重申，請求保護的發明與先前技術之差距是否顯而易見，應回歸通常知識（common sense）之基本原則。易言之，個案事實若為通常知識者「顯然有意願去嘗試」（obvious to try），且有成功之相當期待可能性（with a fair expectation of success），應認為此時已構成顯而易見，發明不符合可專利性要件。

EPO 關於進步性之判斷，雖然是採 could-would 測試法，看似與美國法有所不同。惟細究 could-would 測試法之重點，不在於通常知識者有無「**能力**」（**could**），而是其是否「**有意願**」（**would**）去解決客觀技術問題、考量先前技術的教示進行一定的改良或修正[40]。因此，個案判斷上係著重於通常知識者是否有絲毫的動機去

---

33 專利審查基準（2013 年），頁 2-3-7：審查新穎性時，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，即一發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對。

34 專利審查基準（2013 年），頁 2-3-16。

35 專利審查基準（2017 年 7 月），頁 2-3-17。

36 Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248, 266-267 (1851).

37 Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1, 14-17 (1966).

38 KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727 (2007).

39 DURHAM, *supra* note **Error! Bookmark not defined.**, at 149。

40 EPO, *supra* note **Error! Bookmark not defined.**, at 5.3; 劉孔中、Heinz Goddar、Christain Appelt，前揭註**Error! Bookmark not defined.**，頁 87。

從事及完成發明，通常知識者「有能力」且「有意願」為之，始有否定進步性之可能。就本質與內涵而言，美歐立法例並無實質差異。2025 年間最高法院先後兩則判決(最高法院 113 年度台上字第 459 號及 113 年度台上字第 453 號民事判決)，明確指出 could-would 法則在進步性判斷之重要性[41]。

<<最高法院 113 年度台上字第 453 號民事判決(113 年度台上字第 459 號民事判決亦有類似見解)>>

(二)新型係運用申請前既有之技術或知識，而為通常知識者所能輕易完成時，雖無核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項所列情事，仍不得依專利法申請取得新型專利，此觀同法第 22 條第 2 項規定固明。惟新型是否滿足進步性要件，須與先前技術進行比較，循進步性之審查原則(整體審查、結合比對及逐項審查)，以「新型欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點，依下列步驟判斷：①確定申請專利之新型範圍；②確定相關先前技術所揭露之內容；③確定該新型通常知識者於專利申請時之技術水準；④確認該新型與相關先前技術所揭露內容間之差異；⑤評估通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請前既有之技術或知識，能否輕易完成申請專利之新型。於個案具體操作上，不能單純拆解新型之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對。

(三)通常知識者能否基於先前技術而輕易完成，尚須區辨「顯然有意願嘗試」與「顯然有意願執行」(could-would 法則)。易言之，進步性認定之重點，非僅理論上能否執行成功，尚包括個案有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使通常知識者執行研發及成功。而通常知識者面對引證案時，何以會擷取各引證案之部分技術特徵加以組合，以成就新型之技術特徵，不易由外觀察明，為便於自外部證據認定通常知識者之主觀想法，應考量引證與該新型技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議等因素，其因素越多者，越有結合之動機而否定進步性。

(四)原審固認定乙證 2 單獨或乙證 2、4 之組合，或乙證 1、2、4 之組合，足證專利 1 請求項 1 至 4、7 至 10 不具進步性；乙證 2、8 及先前技術之組合，可見專利 2 更正後請求項 1 不具進步性；乙證 2、6、8 及先前技術之組合，足徵專利 2 更正後請求項 4 不具進步性；乙證 2、8、9 及先前技術之組合，可知專利 2 更正後請求項 8 不具進步性；乙證 6、8、9 及先前技術之組合，堪認專利 2 更正後請求項 1、4、8 不具進步性。然依上開規定及說明意旨，系爭專利之進步性判斷，須先確定通常知識者於系爭專利申請時之技術水準，而以其基於專利申請時通常知識之理解為基準，確認系爭專利與先前技術之差異，進而評估通常知識者能否輕易完成系爭專利，且須注意區辨 could-would 法則，而為客觀判斷，避免機械性拼湊或組合先前技術，致生後見之明。

(五)上訴人於事實審一再主張：乙證 2 圖 8 之「凹槽」，屬不具實質角度或尺寸意義之尋常「逃角」結構，依機械加工領域之通常知識及經驗，該凹槽構造未揭示精確角度，

[41] 李素華，從新近最高法院兩則判決論進步性判斷之 Could-Would 法則，萬國法律，262 期，2025 年 8 月，

亦不可作為刀片之抵靠面；另否認通常知識者於系爭專利申請時，有組合上開引證之動機等語，並提出國立臺灣大學機械工程學系劉正良教授出具之專家意見書為證…此皆攸關系爭專利是否具進步性之判斷，自應調查審認。原審未說明上訴人上揭主張及所提證據何以不可採之理由，且缺乏判斷進步性所需確定通常知識者於系爭專利申請時之技術水準步驟，逕以前開理由認定系爭專利請求項不具進步性，除有不適用法規及適用不當之違背法令外，並屬不備理由。

<<最高行政法院判決 106 年度判字第 651 號>>

一、緣參加人前於民國 102 年 10 月 4 日以「電動刨刀刀具座結構改良」向被上訴人申請新型專利（申請專利範圍共 6 項，第 1 項為獨立項，其餘請求項為附屬項），經被上訴人形式審查後，於 102 年 11 月 27 日核准專利，嗣參加人繳納證書費及第 1 年專利年費後，被上訴人於 103 年 1 月 11 日公告並發給第 M469998 號專利證書（下稱系爭專利）。上訴人於 103 年 8 月 14 日以系爭專利違反 100 年 12 月 21 日修正公布、102 年 1 月 1 日施行之專利法（下稱核准時專利法）第 120 條準用第 22 條第 2 項及第 26 條第 2 項之規定，對之提起舉發，經被上訴人審查，於 105 年 3 月 22 日以(105)智專三(三)05053 字第 10520338300 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 6 舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回。上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。經原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。…

(六)按審查進步性時，如涉及複數引證（即先前技術）之技術內容的結合，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容，而完成申請專利之發明，尚不得以複數引證之技術內容恣意加以拼湊，即謂該發明為所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成，以免後見之明。判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議等因素。如複數引證間之技術領域完全不具有關連性，通常即難以認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者具有動機能結合複數引證之技術內容。反之，如複數引證間之技術內容的技術領域雖具有關連性，仍須進一步判斷所欲解決問題或所產生功能或作用之共通性，或有無教示及建議等事項，始得認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有無動機能結合複數引證之技術內容。原判決已說明：證據 2 係揭示一種平鉋機刀軸裝置之技術，證據 2 之刀座與系爭專利刀具座本體的外型結構觀之，兩者僅係單純地形狀差異，是證據 2 與系爭專利請求項 1 之差異僅在於：證據 2 鉋刀係整片長度的安裝於鉋刀安裝面上，於轉動時不同刀座上的刀片會重覆刨除相同位置，因此無法達成系爭專利不同刀座上的刀片刨除不同位置的結果，故未揭示系爭專利請求項 1「使得該二刀軸帶動該本體轉動時，係可使在不同之該刀座上的該等刀片刨除不同位置

頁 17-29。

的一待刨物表面」之技術特徵。惟證據 5 的刀盤並不等同於系爭專利的刀座，故證據 5 並未揭露系爭專利請求項 1「可使在不同之『該刀座上』的該等刀片刨除不同位置的一待刨物表面」之技術特徵。證據 5 的螺旋鉋刀既係以複數刀盤（刀盤上鎖固刀片）套置於傳動軸上組合而成，而與系爭專利請求項 1 或證據 2 係將刀片直接鎖固於刀座上的技術並不相同，即無可能將證據 5 的刀盤結構以證據 2 之刀座結構置換，亦無理由將證據 2 的刀座結構改為證據 5 的刀盤結構，二者雖屬鉋刀技術相關領域，惟在技術組合上缺乏明顯的教示或建議，仍難謂具有容易組合的動機等語，經核其認定並未違反前述判斷進步性之法則，上訴意旨主張：原判決認定證據 2、5 之組合無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性之理由，顯有違反經驗法則，判決亦不備理由云云，亦不足採。

(七)關於申請專利之發明是否具有進步性，實務上係依下列步驟進行判斷：(1)確定申請專利之發明的範圍；(2)確定相關先前技術所揭露之內容；(3)確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；(4)確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異；(5)該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。一般而言，與發明相關之先前技術內容，包括：發明所記載之先前技術或舉發證據資料等，均得作為確定上開技術水準之客觀證據。至於如何在個案中客觀確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，必須依據個案之具體證據作為基礎進行論證。此外，由於判斷專利有無進步性之相關事實，往往涉及專門知識，而專利權人、舉發人或其等訴訟代理人、專利專責機關之代理人等，多係具有發明所屬技術領域之相關知識或技能者，是以當事人就「具有通常知識者」及其於申請日之技術水準之認定加以爭執時，自應提出證據加以證明，並具體指明該事實涵攝於個案之先前技術組合後，對於進步性之決定究有何影響。如當事人已於事實審就系爭專利與舉發證據所揭露之內容間有何差異，參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明加以辯論，應認當事人已就該發明所屬技術領域中具有通常知識者及其於申請日之技術水準進行辯論。當事人對於原判決就有無進步性之決定不服，而提起上訴，如仍泛言原判決未說明「具有通常知識者」，或未就「具有通常知識者」進行辯論，而未提出證據具體說明「具有通常知識者」及其於申請日之技術水準為何，暨自該「具有通常知識者」於申請日之技術水準加以判斷，進步性之決定有何不同之具體理由，即難認對原判決有何違背法令已有具體之指摘。…

<<最高行政法院 108 年度判字第 432 號（下級審智慧財產法院 107 年度行專訴字第 29 號行政判決）>>

壹、緣參加人於民國 104 年 3 月 9 日以「螺絲」向被上訴人申請發明專利（原申請專利範圍計 2 項，嗣修正為 1 項），經被上訴人編為第 104107419 號審查，准予專利，並發給發明第 I571569 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人以系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，於 106 年 3 月 31 日對之提起舉發。案經被上訴人審查，認系爭專利未違反前揭規定，以 106 年 10 月 19 日（106）智專三・ 04064 字第 10621060050 號專利舉發審定書為「請求項 1 舉發不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，經濟部以 107 年 2 月 6 日經訴字第 10706300630 號訴願決定駁回，上訴人仍不

服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。因原審認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，嗣經原審判決駁回後，上訴人不服，提起上訴。…

四、經查，證據 2 僅提供木螺絲的排屑溝寬度必須超過螺絲中心線才有足夠排屑容量之教示，並未提供在木螺絲設置排屑溝必須考量結構強度之教示，因此發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據 2 所揭示的內容，並無法輕易想到系爭專利請求項 1 所界定「該排屑部的該第一最大距離為該桿身部之牙外徑的 1/3，而該第二最大距離為該桿身部之牙外徑的 1/2」之技術特徵，證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性等情，原判決業已詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；亦係就系爭專利申請範圍確定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對各請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，合於進步性之比對原則，無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。

<<最高行政法院 109 年度上字第 932 號判決>>

（二）按審查進步性時，如涉及複數引證（即先前技術）之技術內容的結合，應考量該新型專利所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容，而完成申請專利之新型，尚不得以複數引證之技術內容恣意加以拼湊，即謂該新型為所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成，以免後見之明。判斷該新型所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議等因素。如複數引證間之技術領域完全不具有關連性，通常即難以認定該新型所屬技術領域中具有通常知識者具有動機能結合複數引證之技術內容。反之，如複數引證間之技術內容的技術領域雖具有關連性，仍須進一步判斷所欲解決問題或所產生功能或作用之共通性，或有無教示及建議等事項，始得認定該新型所屬技術領域中具有通常知識者有無動機能結合複數引證之技術內容。…

（四）經查，依系爭專利說明書之摘要所載，系爭專利為一種舞台車大型 LED 顯示幕之構造，其係於舞台車之車體上裝設一大型 LED 顯示幕，該大型 LED 顯示幕係由：一主顯示幕及兩側顯示幕拼接而成，該主顯示幕之頂端與底端分別固接一頂桿及一底桿，該頂桿及底桿係固定於車體上，並於邊緣處均成對設有上、下兩穿套管，該兩側顯示幕係分別位在主顯示幕之左、右兩側，其頂端與底端同樣設有一頂桿及一底桿，該頂桿及底桿係得與主顯示幕之頂桿、底桿相搭接，且於邊緣處皆凸設一套接管，該等套接管係可對合穿置入主顯示幕之穿套管間，另以插銷穿經其間，將兩側顯示幕拼接固定於主顯示幕之旁側，藉此組成一各顯示幕間可完全對合相接，而可確保畫面連續不中斷之舞台車大型 LED 顯示幕（見乙證 1 第 92 頁）。原判決詳細分析舉發證據 2 至證據 11 之技術（見原判決第 19 頁至第 25 頁），而認為被上訴人（即舉發人）提出之證據 2 至證據 11 之組合，足以證明系爭專利請求項 1、2 不具進步性，固非全然無見。惟查：

1.證據 2、證據 3、證據 4 所揭示之活動背景板，主要是為提供以多片佈景片（折板），其間以傳統家用鉸鏈（樞葉片）方式連結，使之可折合或展開，以變換背景板之形式，屬傳統佈景舞台車技術領域；證據 5，係利用動力源作動，將層疊擺置之各升降式 LED 顯示器顯示幕拼合成一大型螢幕，屬顯示器升降舞台車技術領域；證據 6 為可折疊式的液晶顯示板電視牆、證據 7 為 LED 字幕，證據 6、證據 7 屬電視牆相關技術領域；證據 8 為一種多個顯示器拼接而成的顯示裝置、證據 9 為可攜式電子產品多屏顯示裝置、證據 10 亦為一種可攜式電子產品折疊螢幕，證據 8 至證據 10 屬可攜式電子產品折疊螢幕應用技術領域。證據 2 至證據 10 分屬不同技術領域，證據群組間之技術領域關連性容有疑慮。且證據 2 至證據 10 所欲解決之問題不同，且似未教示或建議如系爭專利請求項 1 所界定之頂桿、底桿、穿套管與套接管配置連結關係應用於舞台車車體上之技術特徵，且未有如系爭專利舞台車大型 LED 顯示幕藉由頂桿及底桿之內縮和外伸以達對合拼接之功效，是否有組合動機？非無可疑。

2.而證據 2 至證據 10，皆為裝設固定後即不易反覆組合或拆卸，均非可反覆拆組之結構。與證據 11 以快速拆卸結構結合兩本體，藉以達到快速拆裝之作用不同。亦即，證據 2 至證據 10，與證據 11 之作用、功能不具共通性。客觀上似不具結合之動機。

3.又，證據 9 利用樞接軸與收容槽凹凸對合之無縫對接；但證據 2 至證據 8、證據 10、證據 11 均非屬解決大型螢幕對接產生畫面中斷不連續現象發生之無縫對接，且似並無實質隱含結合證據 9 無縫對接之技術內容之教示或建議。

4.綜上，原判決未綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關聯性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議等因素，遽認舞台車所屬技術領域中具有通常知識者，可依據證據 2 至證據 5、證據 8 至證據 11 輕易完成系爭專利請求項 1 之技術特徵，使螢幕形成連續不中斷畫面，自有判決不備理由之違誤。

<<智慧財產法院 107 年民專上字第 32 號民事判決>>

…(三)上訴人（專利權人）主張被證 2 、3 、4 並無組合動機，系爭專利之連接塊（組合塊）不等於被證 3 之連接用管塞，系爭專利之連接板部不等於被證 4 之支撐件，被證 2 、3 、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 至 4 不具進步性，均不足採：

1.上訴人雖主張：被證 2 係在解決雙連接管組間之連接方式，惟證據 2 存在著連接管組設不便，以及連接管與置物層架組設繁瑣的問題，被證 3 在改善連接管中管塞之固定方式，而被證 4 在使置物層架可滑動式置放之方式組設，增加便利性，以及連接管之連接方式，三者所欲解決的問題不同，達成的功能與作用亦有差異，所屬技術領域具有通常知識者，並未有將被證 2 、被證 3 、被證 4 三者加以結合之動機云云。惟查，被證 2 、3 及 4 皆屬作為置物之用的架體，被證 3 說明書第 3 頁〔先前技術〕所載「本創作所述連結用管塞，通常係應用於家俱領域及其組合置物架領域中，藉以作為連接管件與管件。而本創作即是針對所述連結用管塞結構加以探討改良；現有的連結用管塞結

構，…，所述連結用管塞必須強制塞入管件內，就生產業界而言因此多一道組裝程序而造成製造費時、成本徒增而不符較佳產業經濟效益之問題點。是以，針對上述習知結構所存在之問題點，如何開發一種更具理想實用性之創新結構，實使用者所企盼，亦係相關業者須努力研發突破之目標及方向。有鑑於此，創作人…，終得一確具實用性之本創作」，可知被證 3 已教示「置物架技術領域中為解決習知結構所存在『組裝程序而造成製造費時及成本徒增』之問題點，則建議使用被證 3 之連結用管塞及連結構件結構」，藉此可達到被證 3 說明書第 4 頁倒數第 7 行起記載「提供一種構造簡單、易於量產，故其組合過程更為簡單而容易施作，是以，確可讓連結用管塞、連結構件與管件組裝結合達到更加簡易、方便有效率、降低製造成本之較佳產業經濟效益及進步性」之功能，由上述所載，被證 3 已教示或建議「將置物架中管件連結固定方式改以被證 3 之連結用管塞及連結構件方式」，基於被證 3 此等之教示或建議，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，有動機將被證 3 結合被證 2（底座、底架管體及接管部技術特徵）及被證 4（置物層架平行連接板、穿孔、鎖固件技術特徵），而完成系爭專利之創作。據上，被證 2 至 4 具有「技術領域之關連性」及「教示或建議」，是被證 2 至 4 為有動機而能明顯結合者。…

<<智慧財產法院 107 年民專上字第 35 號民事判決>>

…(二)系爭專利二之技術分析：

1.系爭專利二所欲解決之問題：習用風扇結構之前網罩通常具有一外環框及中環框，而外環框與中環框藉由系列輻射狀排列之直線網條予以連接，為避免前述手指誤觸旋轉中扇葉之意外，兩兩相鄰之直線網條，其最靠近外環框處之最大寬幅，亦不得小於一指幅之寬度。此習知結構型態於實際使用經驗中，發現仍存在下述之問題點：一般而言，當扇葉運轉時，其最主要之出風區域，在於其軸部外側至扇葉中心位置處，而習用前網罩上輻射排列直線網條間之最大寬幅，因有不得大於一指幅寬度之限制，且越往中心處就越密集，甚至並排在一起，因而會阻擋風扇環形出風氣流，影響出風效率，且受中央部位過於密集排列之直線網條所組擋之出風氣流，常會因為風切的現象，而產生較大之噪音。再者，習用風扇結構之安裝於後網罩之馬達，通常均是自後網罩之中央處向後延伸，因此整個風扇之重心會往後移，不僅拉長整個風扇結構體積之縱深，提高包裝與運輸之成本外，後移之重心，其與支撐結構之重垂線會產生較大之水平距離，故運轉時較易產生晃動（參照系爭專利二說明書第 1 至 2 頁）。

2.系爭專利二之技術手段：系爭專利二提出一種風扇結構包括：(1)一護網，包括一環箍；(2)一裝設於環箍前緣之前網罩，前網罩係包含有一金屬條彎折成型之第一外環框，第一外環框係向內輻射固接有複數第一支撐肋條，而複數第一支撐肋條上係依序同心等距設置有直徑逐漸增加之環圈；(3)一裝設於環箍後緣之後網罩，後網罩係包含有一金屬條彎折成型之第二外環框，第一外環框與第二外環框係為結構互相對應之結構體，並分別定位於環箍之前緣與後緣，第二外環框係向內輻射固接有複數第二支撐肋條，第二支撐肋條之自由端部係固設有一環體；(4)一裝設於後網罩之支撐結構；(5)一由後往前安裝於環體之馬達，馬達並往前延伸進入後網罩中；(6)一裝設於馬達前端之扇葉，當

馬達驅動扇葉旋轉時，可持續產生往前流動之導出氣流（參照系爭專利二說明書第 2 至 3 頁）。

3.系爭專利二之功效：系爭專利二利用後網罩上所設之輻射狀第二支撐肋條，令後網罩後方因旋動之扇葉所產生之氣流，軸向進入後網罩中；並經扇葉繼續壓縮後，利用前網罩上同心設置之系列環圈，將持續往前流動之旋向導出氣流之風阻降至最低，達到提高風扇之導流效果外，並降低風切所產生之噪音之實用進步性與較佳產業經濟效益（參照系爭專利二說明書第 3 頁）。

4.系爭專利二請求項 1 之內容：系爭專利二申請專利範圍共計 10 個請求項，其中請求項 1、6 為獨立項，其餘均為附屬項…

5.無組合文獻 1 至 3 之動機：

(1)組合文獻 1 至 3 對應揭露系爭專利二請求項 1 之技術特徵：文獻 1、2、3 之組合，雖完全對應揭露系爭專利二請求項 1 所有技術特徵，惟查：・文獻 1 所欲解決之問題係「傳統風扇護網通常藉由多數金屬線材彎曲結合成網框型態，有鑑於此結構型態仍舊存在製程複雜、費時欠缺效率、不良率高及成本高等問題」，而所產生之功效為「大幅提高塑膠風扇護網之網線部周邊端腳與環框間之結合面積與結合穩固強度，以增進其抗外力碰撞的能力，達到有效提昇塑膠風扇護網堅固耐用度、品質與使用壽命」。・文獻 2 所欲解決之問題係「現有家用電風扇普遍均設有安全防護之風葉網罩，大部分風扇網罩固定方式，均通過單獨網罩圈或網罩安裝環固定，此安裝方式需要先將網罩固定後，再用專用工具旋緊螺栓或使用單獨設計之塑膠件鎖緊，在實際使用過程中，會因顧客無專用工具或塑膠件變形，而導致網罩不能固定緊鎖，從而無安全防護作用」，而所產生之功效為「設計合理、結構簡單、安裝使用方便、安全可靠，外形美觀且能夠有效節省成本之風扇，用網罩固定結構及採用固定結構之電風扇」。・文獻 3 所欲解決之問題係「蚊蟲被電壓擊斃時會產生霹啪之噪音，且蚊蟲屍體容易沾黏在電柵上，因而阻礙燈管發出之光線及增添清理上不便。外露之電柵可能造成幼童之誤觸，而受電擊之虞，且圍繞在紫外線燈管周圍之高壓電電擊裝置，燒焦之氣味令人作噁，且蚊蟲被擊斃時會產生刺耳噪音」，而所產生之功效為「具潔淨功能之風扇護網，且不會有前述傳統捕蚊器擊斃蚊蟲時，產生刺耳噪音擾人清夢之問題，達到可令蚊蟲喪失行為能力之風扇護網，為其主要目的者」。…

(2)文獻 1 至 3 在所欲解決之問題及所產生之功效明顯不同：文獻 1、2、3 在所欲解決之問題及所產生之功效，均明顯不相同，且文獻 1、2、3 亦無任何教示，可促使該所屬技術領域中具有通常知識者，將三者所揭露個別對應於系爭專利二請求項 1 之技術內容，加以組合，而完成系爭專利二請求項 1 之創作，是文獻 1、2、3 難謂有組合動機。準此，文獻 1、2、3 之組合，不足以證明系爭專利二請求項 1 不具進步性。

<<智慧財產法院 108 年度行專更（一）字第 6 號行政判決>>

（法院判決）2.被告智慧局又主張，藥物的口服是否具有進步性的部分，需要考慮的是系爭專利的化合物在做口服用藥時，是否有困難度，從系爭專利的技術背景來看，證據 4 已經揭示系爭專利化合物可以口服，且也沒有口服上的困難度，就製藥界或所屬技術領域通常知識者來講，發現可能用在治療陽痿上時，第一個想法就是用來做口服用藥，故系爭專利不具有進步性等云云，惟查：

⑴證據 4 說明書僅揭露化合物可口服用以治療心絞痛、高血壓或充血性心衰竭，並非用以口服治療男性勃起不能，兩者疾病不同，自無法等同比擬，被告智慧局輕易認為可以口服治療心絞痛、高血壓或充血性心衰竭，就合理預期治療男性勃起不能可輕易使用口服方式，其認知恐有後見之明。

⑵再者，口服藥物經腸胃道吸收後必須考量藥物可否達到治療標的器官必要治療濃度，而陰莖動脈又屬體內血液循環末稍，口服投藥是否可以使得藥物到達陰莖，且口服劑量吸收後血液循環至陰莖可否達到治療濃度，而該劑量又不至於產生副作用，就非屬一般例行性工作可完成。

⑶此外證據 4 中化合物透過 cGMP PDE V 之抑制效果，可治療穩定或不穩定之心絞痛、高血壓、充血性心臟衰竭、動脈硬化、支氣管炎、慢性氣喘、過敏性氣喘、過敏性鼻炎或青光眼等，自可理解人體多種組織中均含有 cGMP PDE V ，且證據 4 化合物均對該等 cGMP PDE V 具有抑制作用而產生治療效果，若將證據 4 化合物貿然投予僅罹患勃起不能之病人（無其他心血管疾病），則可能導致因抑制其他組織中之 cGMP PDE V 而產生副作用，基於證據 4 化合物對於陰莖海綿體組織中之 cGMP PDE V 是否具有良好抑制效果並未揭露，而該化合物尚會作用於人體其他組織的 cGMP PDE V，是以，就該項技術者而言，使用證據 4 化合物用以口服治療男性勃起不能，而不會導致病人產生其他副作用，是相當困難的，被告智慧局認為將證據 4 之化合物使用口服方式治療男性勃起不能，不具有進步性，應不可採。

十一、證據 4 、10、13 及 19 之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項 1 及 2 不具進步性？

㈠證據 4 、13、19 具有組合之動機已如前述，證據 10 係探討 cAMP、cGMP、膽鹼性神經及非腎上腺性及非膽鹼性神經竇狀內皮細胞與陰莖勃起之關連性，其中圖 6 揭露 NO 會活化鳥苷酸環化酶（guanylate cyclase ，GC），活化之 GC 則促使鳥苷三磷酸鹽（GTP ）轉變為環鳥苷單磷酸（cGMP）含量上升，造成陰莖海綿體平滑肌舒張，且 cGMP 可透過磷酸二酯酶作用轉變為 GMP ，而 zaprinast 為其磷酸二酯酶之抑制劑，與證據 13、19 同屬探討陰莖勃起的可能機制之技術，是以，證據 10、13、19 亦同具有技術領域之關連性，且證據 10 亦揭露 cGMP 選擇性磷酸二酯酶抑制劑之相關技術，自與證據 4 、13、19 具有技術領域之關連性，已如前述；綜上，故證據 4 、10、13、19 有組合之動機。

（二）請求項 1 ：

1.系爭專利更正後請求項 1 ，其技術特徵在於一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能的口服藥學組成物，其中該口服藥學組成物包含式（I ）化合物，而證據 4 、13、19 之組合不足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性，已如上述；證據 10 主要探討 cAMP、cGMP、膽鹼性神經及非腎上腺性及非膽鹼性（NANC）神經、竇狀內皮細胞與電刺激所導致的陰莖勃起之關連性，而所得結論係膽鹼性神經、NANC 神經與竇狀內皮細胞與陰莖勃起有關，並暗示神經所釋放之 NO 及 cGMP 系統係陰莖平滑肌舒張及勃起的最可能路徑（參證據 10 摘要第 1 、3 段），雖原告主張證據 10 之圖 6 已清楚揭露陰莖勃起時之神經衝動傳導 NO/cGMP 機制與海綿體平滑肌鬆弛之生理過程，以及 cGMP PDE（即 cGMP PDE V）與 cGMP 之關係，從而可推論出陰莖勃起之機轉，以進一步試驗確認以 cGMP PDE 抑制劑是否能治療勃起不能。惟查證據 10 之作者係使用陰莖海綿體注射方式注射 SodiumNitroprusside （一種 NO 釋放劑）至混種狗陰莖（參第 874 頁右欄 Experiment IV 內容），藉以評估 NO 及 cGMP 於陰莖勃起機制所扮演之角色，而證據 10 作者認為 NO 係關於陰莖海綿體及勃起重要之神經傳遞物質（參第 876 頁右欄第 1-7 行），然卻未揭露口服投予 cGMP PDE V 抑制劑用以治療勃起不能之技術內容，且由於不同結構之 cGMP PDE V 抑制劑對於不同物種體內各組織之 cGMP PDEV 抑制能力有別，自無合理動機使用證據 4 之式（I ）化合物用以口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能，且無具有治療成功之合理預期，同前所述，證據 10 並無法彌補證據 4 之不足。

2.承上，系爭專利說明書附件一已揭露 UK-92480（即為系爭專利請求項 1 及 2 所請化合物）之功效及安全性，並以雙盲、不規化，以安慰劑作對照組的試驗，係針對 12 個病人（年齡 36 至 63 歲，均有男性勃起功能障礙），可顯見口服 UK-92480 可以改善勃起，故系爭專利之發明已提供相關人體試驗數據證明系爭專利發明之化合物具有口服治療病人之勃起功能障礙的功效，相較於證據 13、19 之體外試驗及證據 10 使用陰莖海綿體注射方式注射 Sodium Nitroprusside（一種 NO 釋放劑）至混種狗陰莖，藉以評估 NO 及 cGMP 於陰莖勃起機制所扮演之角色，系爭專利說明書附件一所提供之人體臨床試驗結果顯然具有較佳之可信度，並直接證實系爭專利請求項 1 及 2 所請化合物可口服投予至病人治療勃起障礙，更非證據 10 所揭露研究 NO 及 cGMP 於陰莖勃起機制所扮演之角色而推論 cGMP 濃度上升導致陰莖勃起進而有治療男性勃起不能之潛力所可相提並論，綜上，系爭專利說明書所提供之數據，更益證系爭專利之發明相較於證據 10、13、19 之技術內容，具有其進步性。

<<最高行政法院 109 年度上字第 356 號判決>>

・・・再者，證據 l 之發明目的及功效為「防止扇輪轉子於旋轉時脫出、吸引扇輪轉子停止於最佳啟動角度、防止落入啟動死點、降低啟動耗電功率」，證據 2 之發明目的（功效）「最少化模製一體扇葉所需的材料用量、不須扇葉平衡材料，改善模製一體扇葉的堆疊穩定性」，證據 3 之功效為「優異的耐衝壓性及軸承壽命」，證據 8 之功效為「通過簡單的結構、能夠在組裝時提高作業性」，證據 12 之功效為「增加組裝便利性、平衡調整裕度及承載可靠度」。顯然證據 1、2 、3、8、12 欲達到發明目的及功效均不同，各

證據間彼此缺少所欲解決問題及作用、功能之關聯性，即便證據 1、2、3 、8、12 均屬於相關聯或相同散熱風扇技術領域，客觀上亦缺乏彼此組合動機，遑論上訴人以證據 1、2、3、8、12 中之部分結構組合拼湊系爭專利請求項 1 之內容，亦難謂無後見之明，故證據 1、2、3、8、12 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性等情，均據原審說明清楚，核無不合。上訴人主張證據 1、2、3、8、12 同為具有轉軸、輪轂、轉子或轉子殼之馬達構造，並利用上述之作動方法達到其目的及功能，具有功能或作用上之共通性，具有組合動機。原判決針對該些證據之客觀事實並未審酌，亦未對證據 1、2、3、8、12 是否具有解決問題之共通性、或各證據有無明確記載或實質隱含結合不同證據之技術內容的教示或建議進行論斷，原判決有認定事實未憑證據之違法部分等等，亦無足取。

進步性判斷容易流於後見之明，尤其是距離專利申請日（進步性判斷之時點）已久之際（諸如在侵權訴訟階段），易於以嗣後已有商品化產品之狀態認為發明之產生乃「輕易完成」。

（請參見課程所提供之兩則「天下雜誌」報導）

二、不構成顯而易知之發明

相較於先前技術，若發明之整體乃顯而易知者，則不符合進步性之要件。顯而易知，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者以先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期申請專利之發明者。顯而易知與能輕易完成為同一概念[42]。據此，欲符合進步性之發明，必須較先前技術有較優越的結果（superior results），亦即有過去所不知的功能或優點[43]。

發明即便看起來與先前技術雖有差別，但若無法產生較優越結果，不認為有進步性，例如：僅改變構造的統合或分開（making a structure integral or sectional）、改變型態或比例大小、改變零件位置、零件的省略或重複、改變既有程序（reversal of process）、以同等之物取代（substitution of equivalents）[44]。

另外，單純對於現有機械之調整，使其更富於適應性、更正確或更方便，亦不當然認為該發明有解決技術困難或產生技術上的優越結果[45]。

在判斷發明是否較先前技術優異，簡易（simplicity）與否未必為關鍵；即便是將繁複的機械演進為簡易，亦可能該當進步性要件[46]。

實務個案上，系爭發明若能產生無法欲期的功效或產生相乘的功效，往往會

---

[42] 專利審查基準（2013 年），頁 2-3-15。

[43] 楊崇森，<<專利法理論與應用>>，2003，頁 109。

[44] 楊崇森，<<專利法理論與應用>>，2003，頁 113-115。

[45] 楊崇森，<<專利法理論與應用>>，2003，頁 114；Janice M. Mueller, An Introduction to Patent Law, 2006, p. 169.

[46] 楊崇森，<<專利法理論與應用>>，2003，頁 115；ALAN L. DURHAM, PATENT LAW ESSENTIALS, 2004, p. 108, para. 8.9.6.

被認定其較先前技術有技術上的優越性；此外，其他客觀事實或因素在判斷上亦可能有其重要性。

所謂發明若能產生無法預期的功效，不論是產生新的性質或在數量上的顯著變化，均可謂符合進步性要件[47]。諸如發明應用於新目的之用途，若能產生無法預期的功效，則可以符合進步性要件。

於組合發明之情況，發明若僅有相加效果，仍不具備進步性要件，必須產生相乘的功效，在功能上有相互作用，因而產生等比級數之效果[48]。

<<（最高）行政法院判決 84 年判字第 1933 號，民國 84 年 8 月 4 日>>

本案係由排擋鎖之鎖栓，鎖定組件及附屬電子防盜裝置等三個元件構成，而此三個元件構成僅係簡單之組合應用，其構造之改變，難認係利用自然法則之技術思想之高度創作，且本案延時技術、延遲技術係習用技藝之應用，顯而易知未能增進功效，不符發明專利要件。原告雖訴稱，本案乃屬「組合發明」，然所謂「組合發明」，乃係指將複數個既有之構成要件組合而成之發明而言，此種組合必須在整體上要旨「相乘」的效果增進才算是創作，若僅有「相加」之效果，則與發明要件不符。本案乃將已知之排擋桿鎖栓、鎖定組件及附加之已知汽車防盜裝置組合成「汽車防盜系統」，只有「相加」效果，並無「相乘」效果，所以本案之「組合」與發明之要件，並不相符。

具體個案上，發明所產生的功效是否達到「相乘效果」，往往亦是以輔以「發明是否產生無法預期效果」判斷之。

<<智慧財產法院行政判決 101 年度行專訴字第 36 號[49]>>

本件原告所有之發明專利「抑制骨質吸除作用之醫藥組合物」第 1 項：「一種用於治療骨質疏鬆症之醫藥組合物，其包含以亞倫多酸活性成份重量計，70 毫克之選自由亞倫多酸、其醫藥上可接受鹽類或酯類及上述之混合物所構成群組之雙膦酸化物，其中該組合物係呈每週 1 次的單位劑量錠劑」。參加人以其違反核准時專利法第 22 條第 1 項及第 4 項規定，對之提起舉發。經被告（智慧局）審查，認系爭專利違反第 22 條第 4 項規定，作成「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。原告不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂提起本件行政訴訟。

原告主張，所屬技術領域中具有通常知識者縱然結合引證 1 與引證 2，亦不會推論出系爭專利之技術特徵。另主張系爭專利係為一選擇發明，判斷選擇發明是否具進步性之

---

[47] 專利審查基準（2013 年版），頁 2-3-18。關於藥品發明之進步性判斷問題，參見李素華（2016），我國藥品專利保護之現況與未來-從專利連結制度之研擬談起，智慧財產權月刊，216 期（2016 年 12 月）。

[48] 專利審查基準（2013 年版），2-3-19。

[49] 案由事實節錄自：http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=6616.

標準之一在於考量是否為有限的選擇，且該選擇為經由例行工作之普通手段即能得知者云云。

（法院判斷）...按「選擇發明係指從先前技術的較大範圍中，有目的的選擇先前技術未明確揭露之較小範圍或個體作為其技術特徵之發明」。查引證 1 雖僅揭示約 1 毫克至約 500 毫克活性成分的劑量範圍，惟引證 2 已明確建議使用 40 毫克或 80 毫克之亞倫多酸鹽，因此，所屬技術領域中具有通常知識者，基於引證 1 及引證 2 所揭示之內容，並不需從廣泛之劑量範圍進行選擇，也不需從超過 16 類的甲烷雙膦酸衍生物中進行選擇，因為引證 2 已明確指出亞倫多酸鹽（alendronate ，默克公司之 Forsamax）在許多國家均為雙膦酸鹽之目前領先者，已有如前述，並建議使用 40 毫克或 80 毫克之劑量，故系爭專利難稱係從較大範圍之先前技術中選擇較小範圍或個體作為發明之技術特徵者。再者，若選擇發明與先前技術產生同一性質之功效，且所限定之數值具備「臨界性」的意義，即具有更為顯著的同一性質的功效，方能認定該發明非能輕易完成(參經濟部公布之 2004 版專利審查基準第二篇發明專利實體審查第三章專利要件 3.5.6 選擇發明第 2-3-28 頁) ，然查系爭專利說明書並未證明所限定之數值具備臨界性的意義，故原告此部分之主張，亦非可採。...

針對進步性判斷事宜，2017 年 7 月我國專利審查基準修正中明文規定，進步性判斷之否定與肯定因素[50]：

3.4.1 否定進步性之因素
3.4.1.1 有動機能結合複數引證
（1）技術領域之關連性
（2）所欲解決問題之共通性

3.4.2 肯定進步性之因素
3.4.2.1 反向教示
3.4.2.2 有利功效
3.4.2.3 輔助性判斷因素

第四款 進步性認定之其他客觀事實（輔助判斷因素）

從學理而言，進步性判斷係由「所屬技術領域具通常知識者」將申請案之發明與「先前技術」進行比較，似屬明確，惟何謂「所屬技術領域中具通常知識」、「如何結合先前技術」，於實務操作上實屬不易，我國學者、專利申請及法院實務在個案中對此之闡述甚為有限。

[50] 專利審查基準（2017 年 7 月），頁 2-3-18。

實務上關於進步性之判斷，往往需佐以其他個案事實，此即美國法上的secondary consideration，我國專利審查基準亦揭示之[51]。蓋進步性判斷既然如此困難及容易受到諸多主觀因素左右，美國實務近年來更加強調以客觀事實證明進步性之重要性。

CAFC 在諸多判決中明確指出：其他客觀事實往往為進步性最具說服力及中肯的證據（secondary considerations may often be the most probative and cogent evidence of nonobviouness）[52]；即便其他客觀事實未必總為關鍵角色，但明知有其他客觀事實而不納入考量，就是錯誤（when secondary considerations are present, though they are not always dispositive, it is error not to consider them）[53]；其他客觀事實(之重要性)是遠過於「錦上添花」(secondary considerations are more than "icing on the cake"）[54]。相較於國外作法，我國實務並不重視進步性判斷之其他客觀事實。

<<最高行政法院判決 101 年度判字第 829 號>>

….系爭發明專利在商業上是否成功、是否具無法預期的功效、是否足以解決長久以來問題等等（專利審查基準 3.4.2 節參照），為判斷進步性之**輔助因素**，甚至在比較法上尚有：是否長久以來需要、授權與競爭者默認、對系爭發明專利異議舉發者之倣製與讚美等等不一而足，當然均為判斷系爭專利申請進步性之輔助因素，惟**上開進步性判斷輔助因素無非為避免進步性判斷標準不一致而流於主觀或判斷不明時，作為參考判斷之次要參考因素，是若依專利要件進步性判斷步驟，就申請前之先前技術所揭露、教示等之內容，以所屬技術領域中具有通常知識者，確足以判斷申請發明專利係能輕易完成，而不具進步性者，對於僅空言主張輔助因素或所提出理由不足以推翻該進步性判斷者，即無庸再予一一贅論**，原審判決未予以一一論究者，自難謂判決理由不備，要難謂原審判決有違背法令之情事。…

若依前揭最高行政法院見解，其他客觀因素根本沒有適用餘地，顯有疑義。

值得注意的是，最高行政法院 110 年度上字第 597 號判決重新釐清「輔助性判斷因素」之真正意涵。

<<最高行政法院 110 年度上字第 597 號判決>>

⑵判斷該發明所屬技術領域中，具通常知識者，參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明，實務承認有「輔助性判斷因素」，包括：發明具有無法預期的功效、發明解決長期存在的問題、發明克服技術偏見、發明獲得商業上的成功等。所謂「輔助性判斷因素」，係因其進步性評價方法，非直接由先前技術與發明的教示因果關係著手，而是由發明與市場間的關係開展，以確定其技術貢獻

[51] 專利審查基準（2013 年版），頁 2-3-18 至頁 2-3-19。
[52] Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co., 655 F.3d 1364, 1375 (Fed. Cir. 2011).
[53] *In re Huai-Hung Kao*, 639 F.3d 1057, 1067 (Fed. Cir. 2011).

程度，故以「輔助性」名之。除前述輔助性判斷因素外，實務亦承認「有利功效」作為肯定進步性之因素。若申請專利之發明對照先前技術具有「有利功效」，則可判斷具有肯定進步性之因素。

觀諸智商法院判決，迄今僅於少數案件中肯認「商業上成功」之「輔助性判斷因素」。

<<智慧財產法院 107 年行專訴字第 75 號行政判決>>

一、事實概要：

原告前於民國 103 年 1 月 28 日以「食物保溫罩」向被告申請新型專利，申請專利範圍共 12 項，經被告編為第 103201848 號進行形式審查，准予專利（下稱系爭專利），並發給新型第 M480330 號專利證書。嗣參加人以該專利有違核准時即 103 年 3 月 24 日施行之專利法（下稱核准時專利法）第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，認系爭專利違反前揭專利法規定，以 107 年 1 月 25 日（107 ）智專三（一）02064 字第 10720086610 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 12 舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，嗣經濟部以 107 年 8 月 6 日經訴字第 10706307550 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。

二、原告主張略以：

(一)證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利不具進步性：證據 2 為不可摺疊保溫罩，係原告申請之專利技術所製產品（下稱第一代產品），其所製成之產品有收納不方便之缺陷，故加以研發改良而生系爭專利，並以系爭專利製作可折疊產品（下稱第二代產品）；證據 3 為一保溫袋，與系爭專利為一食物保溫罩，相比之下，主要應用層面上具有相當大之差異，且證據 3 之保溫袋領域產品早已於市面上流通，但於系爭專利申請日前均未見有通常知識者結合證據 2 、3 之技術內容，由此可知證據 3 與系爭專利之技術領域並不相關，熟習保溫罩技術之人亦無理由參酌保溫袋而加以改良。

(二)系爭專利符合進步性輔助判斷因素之「商業上的成功」要件：原告所提 google 搜尋圖片資料可知，在系爭專利公告（103 年 6 月 21 日）前皆未見類似產品銷售於市面上，而 103 年系爭專利產品（即第二代產品）推出後，由於是國內第一個出現的可折疊食物保溫罩，故推出時就獨占市場，並成功外銷至日本，但 105 年下半年開始出現仿冒品，使原告權益嚴重受損，系爭專利產品在國內獨占市場優勢已不復見。又證據 2 之第一代產品自西元 2012 年起就已經開始在各通路販售，其銷售時間及曝光程度皆遠高於系爭專利之第二代產品，然侵權者僅仿冒第二代產品，可證系爭專利可折疊的設計讓侵權者看見該產品之商業價值。既然系爭專利申請前於市面上並未見可折疊之食物保溫罩相

[54] Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1380 (Fed. Cir. 1986).

關產品，亦無相關先前技術揭露，而原告係依顧客使用證據 2 不可折疊產品後的建議進行改良，始創作系爭專利，由此可知，食物保溫罩之收納一直是本領域中長期存在之問題，該問題確實影響消費者使用不便，甚至影響消費者之購買意願，系爭專利之可折疊的技術特徵確實成功解決了該問題，顯見系爭專利具有商業上的成功，而有進步性。…

（法院判決）五、本院得心證之理由：

4.按 2017 年版（7 月）專利審查基準第 2 篇第 3 章「3.4.2. 3.4 發明獲得商業上的成功」規定：「若申請專利之發明於商業上獲得成功，且其係由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，則可判斷具有肯定進步性之因素。」依原告所提證據可知，原告擁有我國第 M388896 號（即證據 2 ）及第 M480330 號（即系爭專利）二件新型專利，其中證據 2 為第一代產品，系爭專利為第二代產品，二者之技術特徵差異僅在於該食物保溫罩是否可折疊，依原告所提甲證 11 之照片資料顯示第一代產品早於 2012 年即開始銷售，且持續銷售至今（見本院卷第 422 至 432 頁），其銷售時間及曝光程度皆遠大於第二代產品，然由甲證 8 的 google 搜尋圖片資料可知，自證據 2 公告後至系爭專利申請或公告時，坊間均無人仿冒該無法折疊的第一代產品（參照甲證 8 第 1 至 3 頁， 見本院卷第 379 至 381 頁），而系爭專利 103 年 6 月 21 日公告後至 103 年系爭專利產品（第二代產品）於實體通路銷售時，或 104 年於網路銷售時，市面上僅有原告之可折疊保溫罩產品，並無其他仿冒品出現（參照甲證 8 第 3 至 5 頁，見本院卷第 381 至 383 頁），可見當時原告推出第二代產品後，於國內市場具有獨占地位，然因第二代產品開始在網路上銷售增加曝光度後，105 年起即陸續出現仿冒第二代產品之保溫罩（參照甲證 8 第 6 至 7 頁，見本院卷第 384 至 385 頁），106 年起仿冒者愈進猖獗（參照甲證 8 第 8 至 9 頁，見本院卷第 386 至 387 頁），且販售金額遠低於原告之產品（參照甲證 10，見本院卷第 403 頁），使原告之第二代產品原本獨占市場地位被眾多仿冒者瓜分，進而影響原告第二代產品之內、外銷的銷售數量及金額（見本院卷第 445 至 449 頁、第 337 至 347 頁）。

由上可知，原告第二代產品推出時，坊間並無第三人販售類似的可折疊保溫罩產品，顯見當時系爭專利產品確實在市場上具有獨占之情事；又第一代產品也是保溫罩產品，只是不可折疊，但是第一代產品推出時，坊間並無人仿冒第一代產品，直到第二代可折疊產品推出時，仿冒者才選擇第二代產品仿冒，由此可知，仿冒者是看到第二代產品可折疊技術特徵的獨特性及商業價值而開始仿冒，第二代產品之可折疊設計是造成仿冒者仿冒的重要因素，因此可以認定，第二代產品之商業成功確實是基於系爭專利可折疊設計之技術特徵所直接導致，而不是因為銷售技巧或廣告宣傳所造成，因此，應可認定系爭專利確實具有商業上之成功，而具有肯定進步性之因素。

5.綜上，證據 2 、3 是否有組合動機容有疑義，本件否認系爭專利進步性之因素尚有不足，再一併審酌原告所提的輔助性判斷因素後，本院認系爭專利確實具有商業上的成功而有肯定進步性之因素存在，經綜合考量後，應認系爭專利請求項 1 具有進步性，證據 2 、3 之組合無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

<<最高法院於 111 年度台上字第 186 號民事判決>>

（二）發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習技術者所能輕易完成時，雖無核准時專利法第 20 條第 1 項所列情事，仍不得依專利法申請取得發明專利，此觀諸同法條第 2 項規定亦明。而判斷發明專利是否為熟習技術者，運用申請前既有之技術或知識，所能輕易完成，應依下列步驟判斷：①確定被比對專利之專利範圍；②確定相關先前技術所揭露的內容；③確定被比對專利所屬技術領域中，熟習技術者之技術水準；④確認被比對專利與相關先前技術間之差異；⑤該被比對專利所屬技術領域中，熟習技術者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請時之通常知識，判斷能否輕易完成被比對專利之整體。是以，判斷進步性之重點，在於「熟習技術者，運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成」，當不能機械性比對差異，或僅強調相關先前技術所揭露之內容有無教示、建議、動機等（即所謂 TSM 法則），而忽略「能輕易完成」之要件。

（三）發明專利與舉發證據間所存在之差異，為該專利之重要技術特徵，於審查時，應就該特徵是否為舉發證據所揭露，或為所屬技術領域之熟習技術者，以轉用、置換、改變或組合舉發證據等方式，所能輕易完成各情，詳加審酌。蓋進步性審查，不得以發明說明循序漸進、由淺入深之內容，所產生之「後見之明」，即作成能輕易完成之判斷，逕予認定發明不具進步性；而應將發明專利之整體，與舉發證據進行比對，以該發明所屬技術領域之熟習技術者，參酌申請時之通常知識觀點為客觀判斷。所謂熟習技術者，係指一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識，及執行例行工作、實驗之普通能力，而能理解、利用申請日之前之先前技術者而言。熟習技術者之建立，目的在於排除進步性審查之後見之明，對客觀判斷進步性與否，至關重要。

（四）系爭專利申請日為 84 年 10 月 17 日，被證 1、被證 2、被證 3 之公告或公開日，均早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術等情，既為原審所認定，可見關於系爭專利之進步性判斷，應以該專利所屬技術領域之熟習技術者，參酌 84 年 10 月 17 日時之通常知識觀點為客觀判斷，而不得以其後之通常知識觀點為判斷。上訴人就此主張：系爭專利之名詞解讀，應以該專利發明時，相關同業一般技術人員的意見為準；本件有必要引入 20 多年前所屬技術領域中，具有通常知識者，作為專家證人，以澄清各項技術等語，並聲請訊問盧維藩，以證明系爭專利申請時，通常知識者之技術水平，及引證案能否證明系爭專利不具進步性（分見一審卷（三）163 頁；原審卷（二）385、387、421 至 427 頁、卷（五）267 至 268 頁），依上開規定及說明意旨，自攸關系爭專利之進步性判斷，應予調查審認。惟原判決並未說明其不可採及無調查必要之理由，且乏熟習技術者之認定，即缺少「系爭專利所屬技術領域中，熟習技術者之技術水準」之判斷步驟，逕以上開理由認定系爭請求項不具進步性，除有不適用法規及適用不當外，並屬不備理由。

（五）於審查發明專利之進步性時，為避免流於主觀恣意造成判斷失誤（如後見之明），並得綜合考量下列因素：①發明專利解決長久之需要；②發明專利因取代先前技術之產品，而獲得商業上成功；③授權與競爭者之默認；④侵害者之複製與讚美；⑤無幾

乎同時之發明。上訴人一再陳稱：20 多年前英、美、中、日各國均核准系爭專利；我國語音 IC 業經審酌系爭專利內容而參與授權者，包括義隆電子、凌陽科技、盛群半導體、松瀚科技、瑞昱半導體、佑華微電子、凌通科技等上市公司，以系爭專利技術外銷數以十億計之 IC，堪認系爭專利解決長期存在問題，並獲得商業上成功各情，並提出各國專利說明書或專利公報、授權書首頁為證（分見一審卷（一）45 至 60 頁、卷（二）35 至 38、66 至 69、111 至 112 頁；原審卷（五）35、251 至 255、268 頁、卷（六）42 頁），依上開說明及一般論理經驗，似非全然無據，且影響系爭專利之進步性判斷。原審恝置不論，除有違論理及經驗法則外，並屬判決不備理由。

<<智慧財產及商業法院 111 年度民專上更一字第 11 號民事判決>>

・上訴人無法證明其在商業上的成功係因系爭專利所致:

上訴人於 112 年 5 月 15 日民事陳報六狀第 21、22 頁主張附件 6 之松翰科技公司官網里程碑 July2000 之記載、106 年 8 月 22 日民事準備五狀所附原證 14 之授權契約影本(原審卷二第 66 至 69 頁)可證明系爭專利獲得商業上之成功；依前審卷三第 485 至 497 頁可知義隆微電子公司 EM57000 開發系統、松翰科技公司 SNC700 開發系統、盛群半導體公司 HT87XXX 開發系統均將系爭專利技術應用至產品(上訴人於 112 年 2 月 6 日民事上訴理由一狀第 35、36 頁)；「各家參與授權公司的產品使用說明書證明其編碼系統均應用系爭專利說明書揭示之『端形態』原創特徵，亦含有『端形態』欄位與『事件』欄位分列兩欄位表格的另一系爭專利原創技術特徵，為此各授權應用產品之『端形態』輸入端數目均隨意由廠商或用戶決定，不做限制，可證系爭專利之『獲得商業上重大成功』是源於其獨有的原創技術」(民事上訴理由一狀第 6 頁)云云。惟查，若申請專利之發明於商業上獲得成功，且其係由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，則可判斷具有肯定進步性之因素。上訴人雖主張許多公司參與授權並應用系爭專利技術予其產品之中，然上訴人先前既任職於玩具廠美泰兒公司(Mattel Inc.)，對採購 IC 產品具有影響力，則上訴人舉證之各 IC 公司是否直接因系爭專利技術特徵之故而與上訴人洽談授權即有可疑，且簽訂授權書係一商業行為，背後尚有其他諸多考量因素，取得授權僅為專利權人不對被授權人提起訴訟之約定，被授權人若認為訴訟花費之成本大於授權金額，即有簽訂授權契約的可能，無法直接推論簽訂授權契約係因被授權人肯認系爭專利技術上的貢獻所導致。另外，上述 IC 公司皆為語音 IC 業界具有相當規模之公司，所設計、生產之語音 IC 型號眾多，上訴人並無法證明應用系爭專利技術之產品在上述 IC 公司佔有一定比重，松翰科技公司官網僅記載 MCU IC 出貨量突破 10 億顆，惟該 10 億顆 MCUIC 中究竟多少比重使用系爭專利技術之數量無法得知；市場上亦尚有華邦電子、新唐科技等語音 IC 公司並無參與系爭專利授權，上訴人並無法證明應用系爭專利技術之產品在整體語音 IC 市場的比例，縱有某些產品取得上訴人關於系爭專利技術之授權並於市場販售，但並無法等同系爭專利已取得商業上的成功。且專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，**至於商業上的成功僅為進步性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否或上訴人所提供之進步性輔助性證明資料為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助**

判斷之必要(最高行政法院 102 年度判字第 205 號判決、109 年度上字第 575 號判決意旨參照)，被證 1 及 3 之組合、被證 2 及 3 之組合均足以證明系爭專利請求項 21、27、28、36、37 不具進步性，已如前述，則系爭專利是否獲得商業上的成功，並不影響系爭專利請求項 21、27、28、36、37 不具進步性之結論。

<<最高行政法院 114 年度上字第 229 號判決>>

（四）審查進步性時，若申請人提出輔助性資料，主張申請專利之發明已獲得商業上成功，而具有進步性時，固應予審酌。惟商業上成功僅為進步性之輔助判斷因素，專利產品在商業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素所致，故判斷發明是否具商業上成功之肯定進步性因素，必須其成功是由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素所造成。恩特葛瑞斯公司於原審雖提出系爭專利共同發明人之宣誓書用以佐證系爭專利之發明已獲商業上成功，惟上開宣誓書之內容僅提及恩特葛瑞斯公司販售純三氟化硼，以及系爭專利產品所占總銷售額相對比例，尚無從得知該類產品或競爭公司相類似產品於整體市場之銷售情形與市占比例，恩特葛瑞斯公司復未提出其他事證予以佐證，原判決據此而論系爭專利產品歷經近 10 年之銷售，其總銷售額雖有成長，但總銷售額卻仍不及於純三氟化硼產品一半，尚難認系爭專利已獲商業上成功，並無違誤。上訴意旨主張原審未依職權調查系爭專利已獲商業上成功之情形，而有不適用行政訴訟法第 125 條第 1 項規定之違法，自無可取。

綜合而言，「商業上成功」為進步性判斷之其他客觀因素之一，但進步性判斷時間點依然是以「申請日」為準，於此之際，往往不可能有具體的商業化活動。因此，所謂商業上成功之概念或證明，似不應為「具體證明」有商業上成功的「事實」。歐盟專利審查基準所謂的商業上成功，強調者也是「有商業上成功之期待可能性」（…reseanable expection of success）。

依循美國及德國立法例，若有如下客觀事實存在，發明可能推定有進步性的存在或不存在：

--發明解決長久之需要（long-felt need）或克服技術偏見：發明若能解決長期存在的問題，抑或克服所屬技術領域中具有通常知識者長久以來根深蒂固的技術偏見，應認為該當進步性要件55。

--發明獲得商業上的成功（commercial success）[56]：商業成功的產品，可能被推定其技術內容非顯而易見，否則競爭者可以輕易仿效，稀釋該產

[55] 專利審查基準（2013 年版），頁 2-3-18；楊崇森，<<專利法理論與應用>>，2003，頁 110; ALAN L. DURHAM, PATENT LAW ESSENTIALS, 2004, p. 115, para. 8.9.6.1.

[56] 曾啟謀，主張發明獲得商業上的成功在專利訴訟實務上難以成功？(一)，TIPA 電子報，2014 年 11 月 21 日，https://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=221.

品之獲利性；商業上的成功包括在技術授權上的成功。在具體判斷上，必須商業上的成功與發明的技術優越性具有合理相關，始足[57]。

<<智慧財產法院行政判決 101 年度行專訴字第 7 號>>

...末按，申請專利之發明倘為所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識所能輕易完成，權利人尚得提供下列輔助性資料，包括：(i)發明具有無法預期的功效；(ii)發明解決長期存在的問題；(iii)發明克服技術偏見；(iv)發明獲得商業上的成功，用以證明該申請專利之發明具有進步性，惟因商業上之成功可能源自廠商之商業手段策略，倘欲以商業上之成功克服不具進步性之判斷，權利人除應證明其商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品之情事外，尚應證明商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致。原告雖主張證據 5 之每一廠牌產品之規格均有揭示具有 2 個攝影鏡頭模組，即表示具有前鏡頭之視訊攝影模組具有視訊功能，且不需對產品拆解就可由證據 5 很清楚探知該產品之特徵皆與系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵相同，由證據 5 可知系爭專利在商業上獲得成功，而具有進步性等語。查證據 5 之手機縱均具有 2 個攝影鏡頭模組及系爭專利申請專利範圍第 1 項所揭示之其他技術特徵，然原告並未提出證據證明該商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致，且無法排除係因系爭專利申請專利範圍第 1 、3 項之技術特徵係屬先前技術，而為市場上多數手機所採用，實難僅憑證據 5 即認定系爭專利因商業上之成功而克服不具進步性之判斷。...

--所屬技術領域者之反應：業界的肯認（industry recognition）或所屬技術領域之人的讚賞，可推定技術具進步性；另外，所屬技術領域者之質疑或不相信（expressions of skepticism or disbelief），不認為發明人能解決技術困難，但實際上確能解決者，亦代表其乃非輕易能達成者[58]。

--Copying：發明若廣為第三人所複製，往往係因其技術之優越性，因而可能被推定具有進步性[59]。

--Near-simultaneous invention：若在相近時間內有一定數量的平行發明，可能可以推定該等技術內容乃所屬技術領域具通常知識者能輕易達成或顯而易見者，且往往係因科學技術發展至該階段之必然結果，因而可能被認定欠缺進步性[60]。

第二項 進步性之審查

與新穎性判斷相同，進步性之判斷基準日為專利申請日或優先權日。應注意

[57] Alan L. Durham, Patent Law Essentials, 2004, p. 114, 115, para. 8.9.6.1; Janice M. Mueller, An Introduction to Patent Law, 2006, p. 187 *et seq.*

[58] Alan L. Durham, Patent Law Essentials, 2004, p. 115, para. 8.9.6.1.

[59] Alan L. Durham, Patent Law Essentials, 2004, p. 115, para. 8.9.6.1.

[60] 楊崇森，<<專利法理論與應用>>，2003，頁 112；ALAN L. DURHAM, PATENT LAW ESSENTIALS, 2004, p. 115, 116, para. 8.9.6.1.

者為，在進步性的判斷應避免「事後諸葛」，亦即避免「後見之明」（hindsight）[61]。

我國專利審查基準雖載明進步性判斷之步驟，惟細究其內容，不論是通常知識者、先前技術、輕易完成與顯而易知、其他客觀事實等概念之討論，均甚為簡潔，對於個案審查或當事人欲探求法規適用之明確性，似有不足。另外，即令專利審查基準之論述內容較為有限，司法實務仍可透過個案累積，闡釋進步性判斷之方法步驟及建構法學方法論，然判決中對於前揭攸關進步性認定之重要因素，不乏係一語帶過。觀察我國智慧財產法院之實務運作，過於輕易否定發明進步性之其一原因。美歐國家在界定通常知識者時，特別強調應從實務工作者、競爭同業研發工作者之角度去判斷，於發明所屬技術領域中具備實務操作經驗，乃不可或缺者。因此，不論是在專利審查階段，抑或在侵權訴訟階段，應避免由專利審查官、法官或技術審查官自身之標準去認定進步性，此亦為美國或德國往往有專家證人參與及協助法院判斷進步性之主因[62]。

第三項 欠缺進步性之法律效果

發明欠缺進步性者，應由專利專責機關作成不予專利之處分或由第三人依舉發程序撤銷專利權（第 46 條及第 71 條第 1 項第 1 款）。

第五節 專利申請之優惠期

發明雖有前述公開、公用及公知之行為，專利法第 22 條第 3 項及第 4 項進一步規定不視為新穎性及進步性喪失之事由，此即學理所稱之「無害揭露」或「優惠期」規定。

依 2017 年 5 月 1 日修正施行之條文規定，屬於法條所規定之情況，需在事實發生 12 個月內提出專利申請，始不構成新穎性及進步性喪失。

---

[61] 專利審查基準（2013 年版），2-3-22。關於進步性判斷過程，容易發生「後見之明」的人性弱點討論，參見張哲倫，李素華（2014），專利法之經濟結構—經濟分析理論對於我國專利制度運作之啟發，月旦法學，即將刊登於 2014 年 11 月。

[62] 關於我國進步性判斷實務之檢討，詳見李素華、張哲倫，專利進步性判斷之法學方法論-美、德之借鏡及臺灣實務之檢討，月旦法學，242 期，頁 227-259。